<중간보고서>

근로기준법 적용범위의 합리화 방안

서울대학교 법과대학교수

이 철 수

I. 서 – 연구의 목적 및 방법

현행 근로기준법에서는 업종 내지 근로자의 특성을 고려하지 않고, 적용규모에 따라 근로기준법 규정이 일률적으로 적용되고 있어서 문제가 제기되고 있다. 즉 5인 이상 사업(장)에는 근로기준법령이 전면적용되고, 5인 미만 사업(장)에는 일부규정이 적용되고 있다. 이에 대해서는 규율대상의 특수성을 감안하지 아니하고 규율하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 이 문제는 노동보호법령의 적용범위와 직결되는 기본적인 문제이면서도, 사회경제의 발전에 부응하는 규율의 기본방식을 모색하는 현실적이고 시급한 문제이기도 하다.

본 연구는 이와 같은 규제의 기본 틀에 대하여 선진국에서의 경향들을 참조하여, 업종이나 업무의 성격이나 적용근로자의 특성을 고려하여 합리적인 개선방안을 모색하고자 함을 목적으로 한다. 따라서 근로기준법령을 일률적으로 적용하는 것이 아니라, 업종 및 근무특성 등을 고려하여 유형화할 수 있는 경우에 따라 이론과 실태를 조화시키는 정합적인 규율방안을 탐구하고자 한다.

본 연구는 다음의 내용을 중심으로 행해진다

1) 현행 근로기준법령의 적용범위에 대해 비판적으로 검토하고자 한다. 이를 위해 사업장 규모에 따라 적용 예외를 인정하는 현행법제의 타당성 여부를 분석한다. 이를 토대로 규율되는 법령의 취지를 감안하여 규율의 필요성이 전면적인지 부분적인지를 검토한 후 규율대상 업무내용·업종 특성·사업 규모·근로계약 내용·적용근로자의 특성 등에 따라 구체적 조항의 적용 여부를 분석한다.

2)) 유연안정화를 도모하는 선진국들의 경험을 벤치마킹하여 비교법적 분석을 행하고자 한다. 비교 대상국은 미국, 독일, 프랑스, 일본으로 삼았다. 미국은 업종의 내용과 적용대상 근로자의 특성을 감안하여 규율대상을 달리하고 있고, 독일과 프랑스는 최근 들어와 전통적인 보호법제의 경직성을 완화하고 실업난을 해소하기 위해 적용범위를 탄력적으로 적용하려는 입법적 시도를 행하고 있는 바, 이러한 입법론이 한국에도 적용가능할 수 있는 지를 타진해보고자 한다. 일본은 주 40시간제 적용과정에서 다양한 특례조치 등을 마련하여 규율대상의 특성을 배려하는 입법조치를 취하고 있어 이것이 한국의 법제에 어떤 함의를 지니는지를 검토해보고자 한다.

3) 이와 같은 연구성과를 토대로 우리나라에서의 구체적인 개정방안을 강구하고자 한다. 적용범위의 확대 여부는 입법정책적 사항인지라 원리적인 타당성만을 가지고 가부를 판단할 수는 없고 행정부의 능력· 사용자의 법준수능력 등의 현실적 여건을 종합적으로 고려해야 할 것이다. 중간보고서에서는 현행 근로기준법의 적용범위를 비판적으로 분석하는 작업에 초점을 맞추었다. 외국의 입법례와 새로운 경향은 연구회 회원들의 연구성과를 반영해야 하기 때문에 최종보고서에서 본격적으로 다룰 예정이다.

II. 우리나라 근로기준법의 적용범위

1. 적용범위의 변천

우리나라의 근로기준법은 1953년 처음으로 제정된 이후 1997년 3월 13일 법률 제5305호가 폐지되기까지 정치적 상황의 변화에 따라 크게 5번의 개정이 있었다. 5·16 이후의 1961년 개정, 유신 정권하에서의 1974년 개정, 제 5공화국의 1980년 개정, 제 6공화국의 1987년 및 1989년 개정이 그것이다. 그리고 1997년 3월 13일 근로기준법(법률 제5309호)이 새로 제정된 이후에는 경영상 이유에 의한 해고제한 관련 규정의 개정, 여성보호 관련 규정의 개정, 근로시간단축 관련 규정의 개정, 퇴직금제도 관련 규정의 개정 등 2005년 5월 31일까지 총 8차례의 개정이 있었다.[1)]

그러나 근로기준법의 적용범위와 관련하여서는 시행령에 위임하였기 때문에 그 변화를 추적하려면 시행령 개정사를 살펴보아야 한다.

1989년 3월 29일 개정된 근로기준법(법률 제4099호) 제10조 2항에서는 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에는 근로기준법을 부분적용할 것을 명시하고 있지만 과거에는 사업의 규모와 관련하여 일체 시행령에 위임하였다.

다시말해 1989년 개정 이전의 구법에서는 "본법은 모든 사업 또는 사업장에 적용한다. 다만, ... 대통령령으로 정하는 사업 또는 사업장에는 적용하지 아니한다" 라는 형식으로 적용범위의 원칙만 선언하고 그 구체적 범위에 관해서는 일체 시행령에 위임하였다.

우선 적용범위와 관련되는 시행령은 1954.4.7. 근로기준법시행령의 제정(대통령령 제889호)과 그 후의 1962.9.25.(각령 제977호), 1975.4.28.(대통령령 제7613호), 1987.12.31(대통령령 제12359호), 1998.2.24.(대통령령 제15682호) 시행령의 개정을 들 수 있다.

우선 1954년 제정 시행령에 따르면 적용범위는 모든 사업 또는 사업장으로 하되, 15인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 근로기준법의 적용을 전면 배제하였다(제1조). 따라서 16인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 근로기준법이 전면 적용되었다.

그러다가 1962년 개정 시행령(각령 제977호)에 따르면 적용범위는 3가지로 나누어진다. 즉 15인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 근로기준법의 적용을 전면 배제하였고(제1조 본문), 16인 이상 29인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 전면적용을 원칙으로 하되 퇴직금[2)], 연차유급휴가, 가산임금제에 대해서는 그 적

---

1) 개정법의 자세한 내용은, 한국법제연구원, 대한민국법률연혁집 제 28권, 251면 이하 및 법제처 홈페이지 (http://www.moleg.go.kr) 참조.

용을 제외하였으며(제1조 단서), 30인 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 전면적용하였다. 그 결과 1954년 제정 시행령에서는 16인 이상의 사업장에 대해서는 근로기준법이 전면적용되었으나 1962년 개정 시행령에서는 16인 이상 29인 이하의 사업장의 경우에 근로기준법상 일부 규정이 적용제외됨으로써 적용범위가 오히려 축소되었다고 할 수 있다. 한편, 16인 이상 29인 이하의 부분적용사업장에 적용이 제외되는 규정이 퇴직금, 연차유급휴가, 가산임금제의 3종류에 불과하다는 점이 눈에 띈다. 이들을 배제시킨 입법정책적 동기에 대해서는 참조자료를 찾기 힘들지만 아무튼, 뒤에서 보는 바와 같이, 이 후에도 이러한 사항은 항시 부분적용사업장에서 그 적용이 제외되어 왔다.

1975년의 시행령 개정시에는 전체적으로 적용범위를 확대시켰지만 부분적용사업장에서 적용이 배제되는 항목이 크게 늘어났다.

즉 16인 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 근로기준법을 전면적으로 적용하도록 확대하고 5인 이상 15인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 부분적용하도록 하였으며(제1조 단서) 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 적용이 배제되었다(제1조 본문).

부분적용사업장에 적용되는 조항으로, 법 제2조(근로기준의 조건) 내지 제7조(폭행의 금지), 법 제9조(공민권행사의 보장), 법 제12조(보고, 출석의 의무) 내지 제27조의2(해고의 예고), 법 제29조(예고해고의 적용제외) 내지 제41조(임금의 시효), 법 제51조(사용금지), 법 제53조(근로계약), 법 제54조(임금청구), 법 제58조(갱내근로금지), 법 제64조(안전과 보건) 내지 제73조(행정상의 감독의무-90.1.13.삭제), 법 제78조(요양보상) 내지 제99조(기숙사행활의 보장), 법 제103조(감독관의 권한), 법 제105조(감독기관에 대한 신고), 법 제106조(사법경찰권행사의 제한), 법 제107조(이하 벌칙), 법 제109조 내지 제 112조를 열거하고 있다.

1987년의 시행령 개정시에는 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 전면적용, 5인 이상 9인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 부분적용(제1조 단서), 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에 대해서는 적용을 배제하도록(제1조 본문) 함으로써 그 적용범위가 다소 확대되었다. 다만 부분적용사업장에 적용되는 조항의 내용은 변함이 없다.

1989년도 법개정시에는 근로기준법의 적용대상을 대폭적으로 확대하려는 입법방침을 법률로서 선언하였다. 즉 원칙적으로 사업의 규모와 관련하여서는 5인 이상의 사업장에 대해서는 근로기준법을 전면 적용하도록 하고(제10조 제1항), 4인 이하의 사업장에 대해서도 대통령령이 정하는 바에 따라 부분적용할 것을 법률로서 명시하여 진일보한 태도를 보였다(제10조 제2항). 그리고 이러한 태도는 1997년 3월 13일 제정 근로기준법에서부터 현재까지 유지되고 있다.

---

2) 우리나라에서 퇴직금제도가 도입된 것은 1961년의 법개정 때이다

그런데 1989년도 법개정에도 불구하고 정부가 시행령 개정을 미루어 오다가 약 9년이 지난 1998년 2월 24일이 되어서야 이를 보완하는 시행령 제1조의2를 신설하였고, 4인 이하의 사업장에 대해서 적용되는 구체적인 법규정에 대해서는 별표 1로 정하였다.[3] 그리고 동 시행령 별표 1은 2001.10.31. 한차례 개정된 바 있다.[4] 현행 별표 1의 내용은 다음과 같다.

<표> 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 적용하는 법규정

구 분	적 용 법 규 정
제1장 총칙	제1조 내지 제12조, 제14조 내지 제21조
제2장 근로계약	제22조, 제24조, 제25조, 제26조제1항, 제27조 내지 제29조, 제30조제2항, 제32조, 제35조 내지 제41조
제3장 임금	제42조 내지 제44조, 제46조 내지 제48조
제4장 근로시간과 휴식	제53조, 제54조, 제61조
제5장 여성과 소년	제62조, 제63조제1항·제3항(임산부와 18세 미만자에 한한다), 제64조 내지 제67조, 제68조제2항·제3항, 제69조, 제70조, 제72조
제6장 안전과 보건	제76조
제8장 재해보상	제81조 내지 제95조
제11장 근로감독관 등	제104조 내지 제109조
제12장 벌칙	제110조 내지 제116조(제1장 내지 제6장, 제8장, 제11장의 규정 중 상시 4인 이하 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 적용되는 규정을 위반한 경우에 한한다)

이상의 근로기준법 적용범위에 관한 법규 변천 내용을 도표로 표시하면 다음과 같다:

---

3) 다만, 그 시행시기에 대해서는 1999년 1월 1일부터 적용하도록 하되, 사업주의 법 준수능력을 감안하여 재해보상 중 휴업보상·장해보상·유족보상 등에 관한 일부 법 규정은 2001년 1월 1일부터 적용하도록 하였다.

4) 2001.10.31. 시행령 개정은 2001.8.14. 근로기준법 개정시(법률 제6507호) 여성근로자에 대한 보호규정이 주로 임산부에 대한 모성보호에 관한 내용으로 변경됨에 따라 종래 여성과 18세 미만자의 공통된 보호에 관한 내용 중 18세 미만자의 보호에 관한 사항만 4인 이하 사업장에 적용시키던 것을 임산부의 보호에 관한 사항도 4인 이하 사업장에 확대적용시키는 내용으로 개정된 것이다. 구체적으로 1998.2.24. 별표 1의 신설시에는 제5장 제63조(18세 미만자에 한함), 제68조(18세 미만자에 한함), 제70조(18세 미만자에 한함)로 명시되었으나 2001.10.31. 개정시에는 제63조 제1항·3항(임산부와 18세 미만자에 한한다), 제68조 제2항·3항, 제69조, 제70조로 개정되었다.

<표> 적용범위에 관한 법규변천 일람표

법 률	내 용	시행령	내 용
1953년 제정법	모든 사업 또는 사업장에 적용함을 선언하고, 구체적 범위는 시행령에 위임	1954년 제정령	15인 이하 전면배제 16인 이상 전면적용
		1962년 개정령 (각령 제977호)	15인 이하 전면배제 16인이상 전면적용원칙 (*16~29인 사업장에 대해서는 퇴직금, 연차유급휴가, 가산임금제 적용제외)
1974년 개정법	상 동	1975년 개정령	4인 이하 전면배제 *5~15 부분적용 16인 이상 전면적용
1987년 개정법	상 동	1987년 개정령	4인 이하 전면배제 *5~9 부분적용 10인 이상 전면적용
1989년 개정법	5인 이상의 모든 사업 또는 사업장에 적용함을 선언하고 4인 이하에 부분적용함을 명시	상 동 (시행령 미개정)	상 동
1997년 제정법	상 동	1998년 개정령	*4인 이하 부분적용 (시행령 별표 1로 정함) 5인 이상 전면적용
2001년 개정법	상 동	2001년 개정령	*4인 이하 부분적용 (법상의 여성보호관련규정의 개정으로 인해 별표 1 개정) 5인 이상 전면적용

* 부분적용의 범위: 앞 페이지 참조.

2. 각 단체의 입장

노동계에서는[5] 종래부터 일관되게 근로기준법의 적용범위를 확대해줄 것을 요구하였고, 경영계는 이에 관한 입장표명을 하고 있지 않다.

노동계는 법의 적용확대를 주장하면서 그 이유로 우선 근로기준법의 존재의의를 강조한다. 즉 헌법 제32조 3항은 근로자의 근로조건에 관한 보호를 인간의 존엄성 확보라는 차원에서 보장하고 있고, 이를 확인하는 의미에서 근로조건의 최저기준을 근로기준법으로 규정함으로써 근로자의 생존권을 구체적으로 실현하도록 하고 있다는 점을 강조한다.

그런데 4인 이하 사업장에서 일하는 근로자들은 헌법적 기본권인 근로기준법의 적용에서 제외되어 생존권을 위협받고 있는 실정을 들어 문제의 심각성을 지적하고 있다.

특히 1989년 3월 29일의 근로기준법 개정을 통하여, 4인이하 사업장에도 대통령령에 의해 근로기준법이 적용될 수 있도록 동법 제10조에 명시하고 있으나, 정부가 시행령개정을 미룸으로써 월권을 행하고 있다고 비판하였다.

또한 1998.2.24. 시행령 개정이 있기 전에 노동계는 4인이하 사업장의 근로자가 인간다운 삶을 영위할 수 있도록 8시간 노동제가 정착되고, 법정공휴일, 연·월차휴가, 생리휴가, 산전·산후휴가 등의 각종 유급휴일의 보장과 함께 퇴직금 확보를 위한 근로기준법의 확대적용이 시급하다고 주장하였다. 아울러 근로기준법은 물론 최저임금법, 국민연금법, 의료보험법(현행 국민건강보험법), 고용보험법, 산업재해보상보험법 등의 사회보험법도 적용범위를 확대해야 한다고 주장하였다.

다만, 한국노총측에서는 4인 이하의 영세사업장에도 근로기준법의 규정을 전면적용할 것을 주장한데 반하여, 민주노총측에서는 부분적용을 인정하면서도 적용대상조항을 대폭 확대해줄 것을 주장하는 점에서 약간의 차이가 있었다.

당시 민주노총이 영세사업장에도 반드시 적용되어야 할 조항으로 열거한 것은, 법 제2조 내지 제9조(총칙 중 근로기준법의 기본원리), 법 제12조(보고, 출석의 의무), 법 제14조 내지 제61조(근로기준법상의 정의조항, 제2장 근로계약, 제3장 임금, 제4장 근로시간, 제5장 여자와 소년. 단, 제5장 중 귀향여비와 교육시설에 관한 조항은 제외), 법 제64조(안전과 보건), 법 제78조 내지 93조(제8장 재해보상), 법 제99조(기숙사생활의 보장), 법 제103조(감독관의 권한), 법 제105조 내지 제112조(감독기관에 대한 신고, 사법경찰권행사자의 권한, 제12장 벌칙)의 규정이다.[6]

---

5) 이하 노동계의 입장에 대해서는 전국민주노동조합총연맹, 「노동법 개정안(정책 96-7)」, 1996년 8월 참조.

6) 여기서의 조 문항은 1996년 8월 당시 시행되던 근로기준법을 기준으로 한 것이다. 한편, 1998.2.24. 시행령에서 4인 이하 사업장에 적용되는 법규정에 관한 규정이 신설된 이후에는 근로기준법의 적용범위에 관한 노동계의 입장은 뚜렷이 나타나지 않는다.

1998년 시행령 개정이 행해진 이후에는 2005년 단병호 의원이 적용제외 조항 중 제30조제1항(해고 등의 제한)과 제33조(정당한 이유 없는 해고 등의 구제신청) 및 제55조(가산수당 조항), 제71조(생리휴가)와 제73조(육아시간)를 포함시켜 줄 것을 골자로 하는 법개정안을 제출한 바 있다.

3. 정 리

1) 4인 이하의 영세사업장에 적용이 제외되는 조항들

현재 4인 이하의 영세사업장의 근로기준법 적용범위에 대해서는 1998.2.24. 개정된 시행령에 신설된 제1조의2 및 별표 1에 의해 부분 적용될 조항이 선별되어 있다.

동 별표 1의 내용을 참고로 현행법규 중 적용되지 않는 조항을 정리하면 다음과 같다.

제13조 법령 요지 등의 게시
제23조 계약기간
제26조 제2항 사용자의 근로조건 위반시 손해배상청구 및 귀향여비지급
제30조 제1항 정당한 이유없는 해고 제한
제31조 경영상 이유에 의한 해고의 제한
제31조의2 우선 재고용 등
제33조 정당한 이유없는 해고 등의 구제신청
제34조 퇴직급여제도[7]
제45조 휴업수당
제4장 근로시간과 휴식조항 중 제53조(휴게), 제54조(휴일), 제61조(적용의 제외)를 제외한 전체
제63조 제2항 임산부가 아닌 18세 이상의 여성 근로자에 대한 유해·위험사업에의 사용금지
제68조 제1항 18세 이상 여성근로자의 야간 및 휴일근로 제한
제71조 생리휴가
제73조 육아시간
제6장 안전과 보건 : 산업안전보건법에 의거 부분 적용[8]

---

7) 현행 근로기준법 제34조에서는 퇴직급여제도를 근로자퇴직급여보장법이 정하는 바에 따르도록 하고 있다. 근로자퇴직급여보장법 제3조에 의하면 모든 사업장에 동법을 적용하도록 하고 있기 때문에 상시 근로자 4인 이하 사업장에 대해서도 퇴직급여제도가 적용된다. 다만, 동법에서는 영세사업주의 부담을 완화하기 위하여 부칙 제1조에 의거 상시 4인 이하의 사업장에 대해서는 2008년 이후 2010년을 넘지 아니하는 기간 이내에서 대통령령이 정하는 날부터 시행하도록 함으로써 사용자의 부담 수준 등을 단계적으로 조정하고 있다.

8) 근로기준법시행령 별표 1에서는 제6장 안전과 보건에 관한 장을 4인 이하 사업장에도 적용되는 것으로 명시하고

제7장 기능습득
제9장 취업규칙
제10장 기숙사

위의 내용은 다음과 같이 풀이할 수 있을 것이다

우선 제 1장의 총칙 및 제 2장의 근로계약 규정은 원칙적으로 적용된다.

제1장에서는 근로기준법의 기초개념인 사용자, 근로자, 근로, 근로계약, 임금, 평균임금에 관한 유권해석을 내리고 있고, 근로자의 기본적 생활을 보장하기 위해 최저기준원칙, 노사대등결정의 원칙, 균등처우의 원칙, 강제노동과 폭행의 금지, 중간착취의 배제,[9] 공민권 행사의 보장과 같은 노동헌장적 규정을 담고 있는 바, 이러한 규정은 원리적이고 총칙적인 규정이라 사업의 규모에 따라 규범적 의미를 달리할 필요가 없기 때문이다.

제2장 근로계약편에서는 개별적 근로관계법상의 주요한 도구개념인 근로계약의 법리에 관한 일반적 원칙을 밝히고 있다. 근로자 보호의 정신에 입각하여 민법상의 고용계약의 법리를 수정하여 근로계약의 체결에서 해지(해고)에 이르기까지 상세한 규정을 두고 있다. 우선 계약체결시 사용자가 준수하여야 할 사항으로 근로조건 명시, 단시간 근로자의 근로조건, 위약예정의 금지, 전차금상쇄의 금지, 강제저금의 금지 등의 규정을 두고 있고 해고와 관련하여서는 해고의 정당사유, 경영상 이유에 의한 해고제한, 해고예고제 등의 규정을 두고 있다. 이 외에도 민법상의 일부무효의 법리를 수정하고 계약기간을 1년 이하로 제한하였으며 임금채권에 대해서는 우선특권 또는 최우선변제특권, 사망 또는 퇴직 후의 금품청산과 미지급 임금에 대한 지연이자 등을 인정하고 있다. 이들 규정은 근로계약의 원리적 성격을 규명한 것이기 때문에 사업의 규모에 따라 적용을 배제할 이유가 없을 것이다.

다만, 4인 이하의 사업장에 대해서는 제23조 근로계약기간, 제26조 제2항의 사용자의 근로조건 위반시 노동위원회에의 손해배상청구 및 귀향여비지급, 제30조 제1항 정당한 이유없는 해고 제한, 제31조의 경영상 이유에 의한 해고의 제한, 제33조의 노동위원회에의 부당해고 등의 구제신청, 제34조상의 퇴직급여제도 등의 적용을 배제하고 있다.

임금(제3장), 재해보상(제8장) 등 주요한 근로조건에 관해서는 이를 원칙적으로 적용한다. 근로조건의 내용과 수준은 근로자보호의 요체이기 때문에 근로기준법이 부분

있다. 그런데 1990년도 법개정시 안전과 보건에 관한 근로기준법의 관련규정은 삭제되고 산업안전보건법에 정하는 바에 따르도록 개정되었는 바, 현행 산업안전보건법은 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업에 대해서는 일부 규정만을 적용시키도록 하고 있다(산업안전보건법 제3조 제1항, 동 시행령 제2조의2 제1항, 별표 1). 결국 4인 이하의 사업장은 산업안전보건법상의 안전과 보건에 관한 규정이 일부만 적용된다(구체적인 일부적용규정은 동법 시행령 별표 1 참조).

9) 1975년 시행령 개정시에는 근로기준법상의 중간착취의 배제 규정을 근로기준법이 부분 적용되는 영세사업장에 적용되지 않는 것으로 하였으나 1998년에 개정된 시행령에서는 4인 이하 사업장에 대해서도 중간착취배제 규정을 적용하도록 하고 있다.

적용되는 4인 이하의 영세사업장에도 이를 적용할 필요가 있기 때문이다. 여기에 대해서는 몇가지의 중요한 예외가 설정되어 있다.

첫째, 제3장의 임금에 관한 규정 중에서도 휴업수당은 적용이 배제된다.

둘째, 제4장의 근로시간과 휴식에 관한 규정은 제53조(휴일), 제54조(휴가), 제61조(적용의 제외)를 제외하고는 그 적용이 모두 배제된다는 점이다

셋째, 제5장의 여성과 소년의 보호규정은 적용되는 것을 원칙으로 하되, 임산부가 아닌 18세 이상의 여성근로자에 대한 제한 규정과 생리휴가와 육아시간은 적용되지 않는다.

넷째, 제6장의 안전과 보건에 관한 사항은 4인 이하의 영세사업장에 대해서도 적용하는 것을 원칙으로 하되, 산업안전보건법에 의거 4인 이하의 영세사업장에 대해서는 부분적으로 적용된다.

다섯째, 현실적인 고려를 하여 제7장의 기능습득, 제10장 기숙사에 관한 규정은 적용되지 않는다.

여섯째, 제9장 취업규칙은 상시 10인 이상의 사업장에 그 작성의무를 부과하고 있기 때문에 4인 이하의 영세사업장에 대해서는 전면적으로 적용이 배제된다.

2) 적용제외의 이유

4인 이하의 영세사업장에 대해서 위의 규정들을 적용하지 않도록 한 이유에 관해서는 관련 설명자료를 찾기 힘들지만, 다음과 같은 사정에 기인한 것으로 추측해 볼 수 있을 것이다.

첫째가 행정감독상의 어려움을 고려한 듯 보인다.

여기에 속한 것으로 제26조 제2항의 사용자의 근로조건 위반시 노동위원회에의 손해배상청구 등, 제33조의 노동위원회에의 정당한 이유없는 해고 등의 구제신청 등에 관한 행정구제 관련 조항을 들 수 있을 것이다.

둘째로 사용자의 법준수능력을 고려한 듯 보인다

여기에 속한 것으로 제30조 및 제31조 등의 해고제한 규정, 제34조의 퇴직급여제도, 제45조의 휴업수당, 제73조 육아시간, 제7장의 기능습득, 제10장 기숙사에 관한 규정, 10인 이상의 사업주에게 작성의무가 있는 제9장 취업규칙에 관한 장 등을 들 수 있을 것이다.

세째로 법과 현실과의 괴리가 심해 규범으로서의 실효성이 떨어지는 경우에는 그 적용을 배제한 듯 보인다

근로시간제와 휴식에 관한 규정이 대표적인 예라 할 수 있다. 또한 연소자와 임산부를 제외한, 즉 18세 이상의 일반 여성근로자의 보호를 목적으로 유지되고 있는 야간 및 휴일근로제한 등도 여기에 속한다고 할 수 있다.

넷째로 제도자체의 타당성에 관하여 논란이 있을 수 있는 경우이다.

제71조상의 생리휴가제나 제23조의 계약기간의 제한에 대한 규정이 여기에 해당된다고 해석할 수 있다.

이들 적용배제요인은 다분히 편의적인 것이라 할 수 있다. 따라서 하나의 조문이 다수의 요인에 중첩되는 경우도 있을 수 있고 각 요인간에 논리적 연관성을 지니고 있지 않음은 물론이다. 그러나 향후 4인 이하의 영세사업장에 적용되어야 할 조항을 확대, 정비함에 있어 일응의 판단규준으로 활용할 만한 가치는 있다고 생각된다.

이상을 도표로 표시하면 다음과 같다

<표> 근로기준법의 영세사업장 적용배제의 사유

적용배제 사유	항 목
행정감독상의 어려움	제13조 법령요지 등의 게시, 제26조 제2항 사용자의 근로조건 위반시 노동위원회에의 손해배상청구 등, 제33조 노동위원회에의 정당한 이유없는 해고 등의 구제신청
사용자의 능력	제30조, 제31조의 해고제한, 제34조 퇴직급여제도, 제45조 휴업수당, 제73조 육아시간, 제7장 기능습득, 제9장 취업규칙, 제10장 기숙사에 관한 규정
법의 실효성 미흡	제4장 근로시간과 휴식에 관한 규정, 제63조 제2항 임산부가 아닌 18세 이상의 여성근로자에 대한 유해,위험사업에의 사용금지, 제68조 제1항 18세 이상 여성근로자의 야간 및 휴일근로 제한
제도적 타당성 논란	제23조 계약기간의 제한, 제71조 생리휴가

3) 기타 개별적 근로관계법과 사회보험법의 적용 범위

노동관계법에서 상시 사용되는 근로자의 수를 기준으로 판단하는 '사업장의 규모'에 따른 적용배제, 일부적용, 일부배제, 전면적용은 다음의 표와 같다.

<표> 사업장의 규모에 따른 적용 및 배제 범위

제 도	법 령	사업규모에 따른 적용배제	비 고
법정근로기준	근로기준법 제10조, 시행령 제1조의2, 별표1	4인 이하	일부적용
최저임금제	최저임금법 1986.12.31. 제3조 시행령 1987.7.1. 제2조	제조업아닌 모든 사업 9인 이하 제조업	
	시행령 1988.7.7. 제2조	제조업·광업·건설업 아닌 모든 사업 9인 이하 제조업·광업·건설업	
	시행령 1989.7.4. 제2조	9인 이하	
	시행령 1999.3.17. 제2조	4인 이하	
	최저임금법 2000.10.23. 제3조 (예외없음)	근로자를 사용하지 않는 사업	
	시행령 2004.3.17. 제2조	4인 이하 (법령미정비로 보임)	
남녀고용평등	남녀고용평등법 1987.12.4. 제3조 제1항	근기법 적용 사업장 아닌 사업장	
	시행령 2001.10.31 제2조	4인 이하	일부 배제
임금채권보장	임금채권보장법 제3조	산재법 적용 사업장 아닌 사업장	
산업안전보건	산업안전보건법 1981.12.31. 제3조 시행령 1982.8.9. 제3조 제6호	상시 4인 이하	
	산업안전보건법 제3조 시행령 1986.4.8. 별표 1	상시 4인 이하	일부적용 ⇓ 추가 ⇓ 일부적용
	시행령 2000.8.5. 제2조의2, 별표 1	상시 4인 이하	

물론 모든 노동관계법을 망라한 것은 아니지만 여전히 대부분의 법령이 4인 이하 사업장에 대해서 일부적용, 일부 적용배제, 전면적 적용배제하고 있다. 오직 최저임금법만이 근로자를 사용하는 모든 사업장에 적용되고 있을 뿐이다[10].

그런데 사회보험의 경우를 보면 상당히 다른 양상을 보여주고 있다. 아래 표는 4대 사회보험이 사업규모에 따라 어떻게 적용이 확대되어 왔는가를 아주 간략히 제시한 것이다[11].

---

10) 최저임금법의 경우 2000.10.23.자 법개정에 의하여 시행령으로 '사업의 규모에 따른 적용제외'를 정할 모법의 근거가 없어졌고 실제로 2001년 9월부터 적용되는 최저임금에 관한 고시는 모든 사업장에 적용되고 있음에도 불구하고, 현행 시행령(2004.3.17.자 개정 대통령령 18312호) 제3조는 여전히 4인 이하 사업장에 대해서 적용을 배제하는 문언이 그대로 남아 있다.

11) 정인섭, 근기법 개정방안 검토의견, 근로기준법 개정을 위한 공청회(비정규·소외 노동자보호/근로기준의 실효성 확보), 단병호의원/노동인권 실현을 위한 노무사 모임, 2005.8

<표> 4대 사회보험의 적용범위

제 도	법 령	사업규모에 따른 적용배제	비 고
산업재해보상보험	산업재해보상보험법 1963.11.5. 제4조 시행령 1964.6.9. 제2조	499인 이하	⇓ 적용확대 ⇓
	시행령 1986.8.27. 제2조	4인 이하	
	시행령 2000.6.7. 제3조	단속적 사용으로 1인 이상이 되지 않는 사업 농업·임업·어업·수렵업중 4인 이하	
	시행령 2003.5.7. 제3조 제1항 제5호	1인 이상이 되지 않는 사업	
	시행령 2003.5.7. 제3조 제1항 제6호	농업·임업·어업·수렵업중 비법인 4인 이하	
고용보험	고용보험법 1993.12.27. 제7조 시행령 1995.4.6. 제2조 제1항	상시 10-49인 상시 9인 이하	일부배제 전부배제
	고용보험법 제7조 시행령 1998.2.12. 제2조 제1항	상시 4인 이하	
	고용보험법 제7조 시행령 1998.10.1. 제2조 제1항 제1호	농업·임업·어업·수렵업중 4인 이하	
	고용보험법 제7조 시행령 2002.12.30. 제2조 제1항 제1호	농업·임업·어업·수렵업중 비법인 4인 이하	
국민연금 당연적용 사업장	국민복지연금법 1973.12.24. 제8조 시행령 1974.1.4. 제6조 제1항	상시 29인	
	국민연금법 제8조 제1항 시행령 1987.8.14. 제19조 제1항 제1호	상시 9인 이하	
	국민연금법 제8조 제1항 시행령 1991.8.10. 제19조 제1항 제1호	상시 4인 이하	
	국민연금법 제8조 제1항 시행령 2003.6.27. 제19조 제1항 제1호	1인 이상이 되지 않는 사업	
의료보험 당연적용 사업장·국민건강 보험 직장가입	의료보험법 제7조 제1항 시행령 1977.3.14. 제4조 제1항	상시 499인 이하	⇓ 적용확대 ⇓
	시행령 1988.7.22. 제4조 제1항	상시 4인 이하	
	국민건강보험법 1999.2.8. 제6조 제2항 제1호 시행령 2000.6.23. 제10조 제1항	상시 4인 이하 고용형태등의 적용제외	
	국민건강보험법 2000.12.29. 제6조 제2항 제4호 시행령 2001.6.30. 제10조 제1항 제1호	농업등에서 4인 이하	전 부 배 제
	국민연금법 제8조 제1항 시행령 2003.6.27. 제19조 제1항 제1호	근로자가 없거나 비상근·시간제 근로자만 사용	

위의 표에 나타난 바와 같이 개별적 근로관계법과는 달리 비법인이 농업·임업·어업·수렵업을 하는 경우가 아닌 한 현재 이른바 4대보험이 전면 적용되고 있다.

III. 4인 이하 영세사업장의 근로실태[12)]

1. 임금실태

○ 상용근로자 4인이하 소규모사업체에 종사하는 근로자에게 지급된 '04.10월의 1인당 월급여액(정액+초과급여)은 1,201천원으로 전년('03)의 1,156천원에 비해 3.9% 상승

- 금년 조사결과에 따른 전년('03)도에 지급된 1인당 연간특별급여액은 989천원으로 '02년의 982천원에 비해 0.8% 상승

※ 이는 상용근로자 5인이상 사업체의 1인당 월급여액(1,801천원) 대비 66.7%, 연간특별급여액(5,525천원) 대비 17.9%수준

(단위 : 천원, %)

	월급여액 (정액+초과급여)		연 간 특별급여		5인이상 사업체(매통조사)	
		증감률		증감률	월급여액	연간특별급여
2004	1,201	3.9	-	-	1,801(6.4)	-
2003	1,156	5.8	989	0.8	1,693(8.4)	5,525(11.4)
2002	1,093	7.9	982	3.3	1,562(12.7)	4,959(13.4)
2001	1,013	5.8	950	15.8	1,386(3.2)	4,375(3.4)

* 1. 5인이상 사업체의 1인당 월급여액(정액+초과급여) 및 연간특별급여액(상여금 등)은 동일기간의 「매월노동통계조사」 자료이며, ( )안은 전년대비 증감률임
2. 통계단위이하의 수치는 반올림되었으므로 계산된 결과와 일치하지 않을 수도 있음

2. 근로자의 그룹별 월급여액

1) 성별 월급여액

○ 남자 근로자의 월급여액을 100으로 할 때 여자 근로자의 월급여액수준은 71.3으로 전년(70.1)에 비해 성별 임금격차를 소폭 축소

- 5인이상 사업체의 수준이 65.0임을 감안할 때 소규모사업체의 성별 임금격차는 오히려 더 작게 나타남

---

12) 노동통계 홈페이지 온라인 간행물 자료 (http://laborstat.molab.go.kr/newWeb/intro/info_soho.jsp?PageNum=5) 중 "2004.10월기준 소규모사업체근로실태조사 결과" 내용임

※「매월노동통계조사」에 따르면 여자 근로자의 월급여액 1,313천원은 남자의 2,020천원에 비해 65.0수준에 그침

(단위 : 천원, %)

	2004	2003	2002	2001
남 자	1,397 (100.0)	1,354 (100.0)	1,276 (100.0)	1,183 (100.0)
여 자	996 (71.3)	950 (70.1)	905 (71.0)	831 (70.2)

2) 학력별 월급여액

○ 고졸학력 근로자의 월급여액을 100으로 할 때 대졸이상 학력 근로자의 월급여액 수준은 125.1으로 전년의 123.3에 비해 다소 확대

- 평균연령과 경력년수가 짧은 전문대졸 근로자는 고졸근로자 대비 98.4수준의 월급여액 받음

(단위 : 천원,%)

	중졸이하	고 졸	전문대졸	대졸이상
2004	1,026 (88.4) [-0.8]	1,160 (100.0) [2.8]	1,142 (98.4) [6.4]	1,451 (125.1) [4.4]
2003	1,034 (91.7) [3.2]	1,128 (100.0) [5.9]	1,072 (95.1) [5.4]	1,390 (123.3) [6.4]
2002	1,003 (94.1) [8.2]	1,065 (100.0) [9.1]	1,018 (95.5) [5.6]	1,306 (122.6) [4.4]
2001	927 (93.5) [7.0]	976 (100.0) [5.4]	963 (98.7) [4.9]	1,252 (128.3) [6.9]

* ( )내는 고졸근로자 월급여액 100으로 한 지수이며, [ ]내는 전년비 임금상승률임

3) 학력별, 연령계층별 월급여액 수준

○ 연령계층별 월급여액 추이를 보면「20～24세」의 월급여액을 100으로 했을 때「45～49세」계층에서 154.9로 가장 높은 수준을 보임

- 대졸이상 근로자는「50～54세」에서 210.7(2.1배), 고졸 근로자는 「45～49세」에서 144.8(1.4배) 수준으로 임금상승의 정점을 보임

- 중졸이하 근로자는 노동집약적 근로를 많이 하는 데 기인하여 「20～60세 미만」연령계층구간에서는 임금수준의 차이가 거의 없음

(단위 : %)

		20~24세	25~29세	30~34세	35~39세	40~44세	45~49세	50~54세	55~59세	60세 이상
2004	전학력	100.0	119.1	138.8	147.5	149.4	154.9	148.6	145.9	128.1
	대졸이상	100.0	119.5	146.1	170.1	187.7	203.1	210.7	206.8	193.1
	전문대졸	100.0	119.1	142.2	153.3	158.4	163.4	206.6	177.1	161.1
	고 졸	100.0	118.3	133.6	138.2	141.2	144.8	141.7	142.6	127.6
	중졸이하	100.0	96.6	109.3	101.2	98.2	105.9	97.9	100.8	87.9
2003	전 학 력	100.0	117.8	138.0	146.0	149.6	150.5	146.9	143.8	121.3
2002	전 학 력	100.0	120.1	140.9	150.4	147.9	151.3	154.7	138.2	128.6
2001	전 학 력	100.0	123.1	144.3	157.4	155.4	155.9	150.3	143.3	132.0

* 주 : 20~24세 월급여액 100으로 한 지수임

4) 경력년수별 월급여액 수준

○ 1년미만 근로자의 월급여액을 100으로 할 때 10년이상 근로자의 월급여액 수준은 159.3로 전년의 163.7보다 4.4p 축소

- 남자 10년이상 경력 근로자의 월급여액 수준은 154.1로 전년의 153.6보다 0.5p 확대

- 여자의 경우 136.8로 전년의 143.2보다 6.4p 축소

(단위 : %)

		1년 미만	1 ~ 2년	3 ~ 4년	5 ~ 9년	10년이상
2004	계	100.0	109.2	119.8	135.7	159.3
	남자	100.0	110.2	122.5	135.0	154.1
	여자	100.0	107.1	114.1	126.3	136.8
2003	계	100.0	108.7	123.0	136.2	163.7
	남자	100.0	107.8	121.8	133.2	153.6
	여자	100.0	108.9	118.8	125.0	143.2
2002	계	100.0	112.3	124.9	139.6	166.7
	남자	100.0	114.7	127.1	139.9	159.8
	여자	100.0	109.1	117.2	126.8	144.2
2001	계	100.0	109.1	119.1	134.4	158.2
	남자	100.0	110.1	119.8	132.4	150.6
	여자	100.0	106.5	114.1	122.9	133.9

주 : 1년미만 월급여액을 100으로 한 지수임

3. 근로자 구성 및 분포

1) 근로자 구성

○ 4인이하 사업체에 종사하는 근로자의 평균연령은 37.3세로 전년의 36.5세보다 0.8세 증가하였으며, 지속적인 증가추이를 보임

○ 평균 근속년수는 3.6년으로 전년의 3.3년에 비해 0.3년 증가함

- 남·여 근로자 모두 지속적으로 증가추이

○ 전체 근로자에서 고졸근로자의 구성비는 52.2%로 지속적인 감소추이

- '04년(52.2%) ← '03년(52.5%) ← '02년(53.5%) ← '01년(55.3%)

- 또한, 전문대졸 근로자의 비율도 17.1%로 전년(17.7%)에 비해 소폭 감소

- 반면, 대졸이상 근로자 비율은 20.1%로 전년(18.5%)에 비해 1.6%증가하여 소규모 사업체의 고학력화 현상이 두드러짐

(단위 : 세, 년, %)

.

		2004	2003	2002	2001
연 령	계	37.3	36.5	35.7	35.6
	남 자	39.3	38.5	37.7	37.4
	여 자	35.2	34.4	33.7	33.6
근속년수	계	3.6	3.3	3.0	2.9
	남 자	4.4	4.0	3.7	3.6
	여 자	2.7	2.6	2.4	2.3
학력별 근로자 구성	계	100.0	100.0	100.0	100.0
	중졸이하	10.6	11.3	11.6	12.4
	고 졸	52.2	52.5	53.5	55.3
	전문대졸	17.1	17.7	16.9	16.1
	대 졸	20.1	18.5	17.9	16.3

2) 임금계층별 근로자 분포

○ 40만원미만 임금계층의 근로자 구성비는 0.4%수준으로 전년의 0.6%에 비해 소폭 감소

- 100만원미만 임금계층의 근로자구성비(35.9%)가 전년(41.2%)에 비해 감소한 반면, 100만원이상 임금근로자 구성비는 증가하여 임금수준구조의 개선 양상을 보임

(단위 : %)

구성비 / 임금계층	2004	누적구성비	2003	누적구성비	2002	누적구성비	2001	누적구성비
전 체	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-
40만원 미만	0.4	(0.4)	0.6	(0.6)	1.0	(1.0)	0.7	(0.7)
40 ~ 60만원	3.5	(3.9)	4.1	(4.7)	4.5	(5.5)	5.6	(6.3)
60 ~ 80만원	12.8	(16.7)	16.0	(20.6)	15.9	(21.4)	21.5	(27.8)
80 ~ 100만원	19.3	(35.9)	20.6	(41.2)	21.1	(42.5)	23.7	(51.5)
100 ~ 120만원	19.2	(55.1)	17.1	(58.3)	19.4	(61.9)	17.9	(69.4)
120 ~ 160만원	23.6	(78.7)	22.9	(81.2)	21.9	(83.7)	18.4	(87.8)
160 ~ 200만원	10.4	(89.1)	10.0	(91.2)	8.7	(92.5)	6.6	(94.4)
200만원이상	10.9	(100.0)	8.8	(100.0)	7.5	(100.0)	5.6	(100.0)

* 주 : 임금계층 구분은 임금총액기준으로 하였으며 정액 및 초과급여액에 전년도 월평균 특별급여액(전년도 연간특별급여÷12월)을 포함한 금액임

4. 직종별 월급여액, 근로실태

○ 직종별 근로자 1인당 월급여액(정액+초과급여) 수준은 『고위임직원 및 관리자』가 2,106천원으로 가장 높고, 『단순노무직근로자』는 1,009천원으로 가장 낮은 수준

- 주당 근로시간은 『서비스근로자』가 58.5시간으로 가장 길고, 『전문가』는

43.8시간으로 가장 짧음 (평균 49.4시간)

○ 연령은 『고위임직원 및 관리자』가 47.9세로 가장 높은 수준이며, 『서비스근로자』의 근속년수는 1.8년으로 가장 짧아 근로자의 이직 또는 전직이 많은 직종으로 나타남

(단위 : 세, 년, 시간, 천원, %)

구 분	연령	근속년수	주 당 근로시간	월 급여액	학력별 근로자 구성비			
					중졸 이하	고졸	전문대졸	대졸 이상
전 직 종	37.3	3.6	49.4	1,201	10.6	52.2	17.1	20.1
고위임직원 및 관리자	47.9	8.1	45.3	2,106	1.9	34.6	13.0	50.5
전 문 가	33.3	3.4	43.8	1,258	0.1	7.6	38.3	54.0
기술공 및 준전문가	34.4	3.6	44.4	1,245	0.9	36.8	27.0	35.2
사무직근로자	34.6	4.1	46.1	1,207	1.7	47.3	22.8	28.3
서비스근로자	40.0	1.8	58.5	1,043	25.8	63.6	7.4	3.2
판매근로자	34.4	3.6	51.1	1,134	5.0	66.0	14.7	14.3
기능원 및 관련기능근로자	37.5	4.0	49.1	1,243	13.6	68.2	11.8	6.4
장치, 기계조작 및 조립근로자	39.6	4.2	48.2	1,309	16.3	71.9	7.0	4.9
단순노무직근로자	46.5	2.8	55.9	1,009	35.6	56.2	5.4	2.8
2003년 (전직종)	36.5	3.3	50.3	1,156	11.3	52.5	17.7	18.5
2002년 (전직종)	35.7	3.0	51.0	1,093	11.6	53.5	16.9	17.9
2001년 (전직종)	35.6	2.9	50.3	1,013	12.4	55.3	16.1	16.3

*주 : 월급여액은 정액급여 및 초과급여 기준으로 연간특별급여액이 제외된 금액임

5. 직종별, 경력년수별 월급여액 수준

○ 1년미만 경력자 월급여액을 100으로 할 때 1~2년 109.2, 10년이상 159.3으로 경력년수가 늘어나면서 월급여액의 수준도 높아지는 연공서열형 임금형태를 보이고 있음

○ 경력년수별 임금격차가 가장 큰 직종은 『기술공 및 준전문가』로 1년미만 월급여액(100)대비 10년이상 184.4인 반면, 『단순노무직근로자』는 114.1으로 경력과 월급여액 수준의 상관성이 가장 낮은 것으로 나타남

(단위 : 천원, %)

	전경력	1년미만	1~2년	3~4년	5~9년	10년이상
전 직 종	1,201 (125.4)	957 (100.0)	1,045 (109.2)	1,147 (119.8)	1,299 (135.7)	1,525 (159.3)
고위임직원 및 관리자	2,106 (128.7)	1,636 (100.0)	1,680 (102.7)	1,827 (111.7)	2,015 (123.2)	2,269 (138.7)
전 문 가	1,258 (133.7)	941 (100.0)	1,070 (113.7)	1,150 (122.2)	1,363 (144.8)	1,736 (184.4)
기술공 및 준전문가	1,245 (135.1)	922 (100.0)	1,035 (112.3)	1,180 (127.9)	1,313 (142.4)	1,698 (184.2)
사무직근로자	1,207 (125.2)	964 (100.0)	1,047 (108.6)	1,136 (117.8)	1,313 (136.2)	1,523 (157.9)
서비스근로자	1,043 (112.9)	924 (100.0)	983 (106.4)	1,079 (116.8)	1,127 (122.0)	1,219 (131.9)
판매근로자	1,134 (122.9)	922 (100.0)	1,024 (111.0)	1,095 (118.7)	1,281 (138.9)	1,459 (158.2)
기능원 및 관련기능근로자	1,243 (127.0)	979 (100.0)	1,101 (112.5)	1,211 (123.7)	1,315 (134.3)	1,421 (145.1)
장치, 기계조작 및 조립근로자	1,309 (117.3)	1,115 (100.0)	1,185 (106.3)	1,276 (114.4)	1,358 (121.8)	1,460 (130.9)
단순노무직근로자	1,009 (107.9)	935 (100.0)	1,000 (107.0)	1,003 (107.3)	1,068 (114.2)	1,066 (114.1)
2003년 (전직종)	1,156 (127.4)	907 (100.0)	986 (108.7)	1,116 (123.0)	1,236 (136.2)	1,485 (163.7)
2002년 (전직종)	1,093 (128.2)	853 (100.0)	958 (112.3)	1,066 (124.9)	1,190 (139.6)	1,422 (166.7)
2001년 (전직종)	1,013 (124.1)	816 (100.0)	891 (109.1)	972 (119.1)	1,097 (134.4)	1,291 (158.2)

주 : 1. 월급여액은 정액급여 및 초과급여 기준으로 연간특별급여액 제외됨
2. ( )내는 「1년미만」 월급여액을 기준(100.0)으로 비교한 격차임

6. 직종별, 연령계층별 월급여액 수준

○ 연령계층별 월급여액 수준은 40~49세 계층이 1,339천원으로 가장 높으며, 60대 이후에서는 월급여액 수준이 크게 하락

- 「기술공 및 준전문가」는 50대 연령계층까지 월급여액 수준이 상승하는 반면,
- 「서비스근로자」, 「판매근로자」, 「단순노무직 근로자」는 40대부터 월급여액 수준이 하락하는 추세

(단위 : 천원, %)

	전연령	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60세이상
전직종	1,201 (121.0)	993 (100.0)	1,260 (126.9)	1,339 (134.9)	1,302 (131.2)	1,130 (113.8)
고위임직원 및 관리자	2,106 (114.3)	1,842 (100.0)	2,121 (115.2)	2,038 (110.6)	2,298 (124.8)	1,942 (105.4)
전문가	1,258 (126.2)	997 (100.0)	1,328 (133.2)	1,641 (164.6)	1,610 (161.5)	1,976 (198.2)
기술공 및 준전문가	1,245 (127.5)	977 (100.0)	1,253 (128.3)	1,584 (162.2)	1,855 (189.9)	1,384 (141.7)
사무직근로자	1,207 (120.7)	1,000 (100.0)	1,264 (126.4)	1,435 (143.4)	1,415 (141.5)	1,325 (132.5)
서비스근로자	1,043 (118.3)	881 (100.0)	1,094 (124.1)	1,078 (122.3)	1,083 (122.9)	1,055 (119.8)
판매근로자	1,134 (117.8)	962 (100.0)	1,255 (130.4)	1,237 (128.5)	1,196 (124.3)	1,012 (105.2)
기능원 및 관련기능근로자	1,243 (110.9)	1,121 (100.0)	1,267 (113.1)	1,330 (118.7)	1,206 (107.6)	1,012 (90.3)
장치, 기계조작 및 조립근로자	1,309 (115.3)	1,135 (100.0)	1,348 (118.8)	1,366 (120.4)	1,223 (107.8)	1,188 (104.7)
단순노무직근로자	1,009 (98.0)	1,029 (100.0)	1,169 (113.6)	1,118 (108.6)	910 (88.4)	822 (79.8)
2003년 (전직종)	1,156 (120.3)	961 (100.0)	1,225 (127.4)	1,299 (135.1)	1,263 (131.4)	1,050 (109.3)
2002년 (전직종)	1,093 (119.6)	914 (100.0)	1,178 (128.9)	1,214 (132.9)	1,212 (132.6)	1,046 (114.4)
2001년 (전직종)	1,013 (120.2)	842 (100.0)	1,104 (131.0)	1,147 (136.1)	1,088 (129.2)	972 (115.4)

* 주 : 1. 월급여액은 정액급여 및 초과급여 기준으로 연간특별급여액이 제외됨
2. ( )내는 「20~29세」 월급여액을 기준(100.0)으로 비교한 수준임

7. 산업별 근로시간, 월급여액 및 학력별 근로자 구성비

○ 산업별 근로자 1인당 월급여액은 『전기·가스 및 수도사업』이 2,296천원으로 가장 높은 반면, 『교육서비스업』은 931천원으로 가장 낮은 수준임

○ 주당근로시간은 『숙박 및 음식점업』이 58.0시간으로 가장 길고, 『교육서비스업』이 38.8시간으로 가장 짧음

(단위 : 세, 년, 시간, 천원, %)

구 분	연령	근속년수	주당 근로시간	월급여액	학력별 근로자 구성비			
					중졸 이하	고졸	전문대졸	대졸 이상
전 산 업	37.3	3.6	49.4	1,201	10.6	52.2	17.1	20.1
광 업	43.4	4.1	47.8	1,448	28.0	53.9	5.6	12.5
제 조 업	39.2	4.4	47.5	1,305	15.7	63.0	10.7	10.5
전기, 가스 및 수도사업	40.4	11.5	48.0	2,296	10.4	58.8	9.0	21.8
건 설 업	38.2	3.4	46.6	1,240	3.8	54.5	19.2	22.5
도 매 및 소 매 업	35.0	3.8	49.6	1,298	3.3	54.8	18.7	23.2
숙 박 및 음 식 점 업	41.4	1.8	58.0	1,068	31.2	58.2	7.0	3.6
운 수 업	38.2	4.2	47.3	1,259	6.0	46.8	19.9	27.2
통 신 업	35.5	4.8	46.7	1,333	4.0	51.9	19.3	24.8
금 융 및 보 험 업	34.1	7.5	40.3	1,721	0.2	41.2	17.9	40.7
부 동 산 및 임 대 업	49.7	3.7	54.5	1,059	24.8	51.8	10.2	13.3
사 업 서 비 스 업	35.4	4.0	44.8	1,327	1.5	38.8	26.7	33.0
교 육 서 비 스 업	31.5	2.4	38.8	931	0.5	13.4	37.3	48.8
보건 및 사회복지 사업	30.5	3.1	46.4	1,022	1.3	50.4	33.5	14.9
오락, 문화 및 운동관련산업	35.0	3.5	47.7	1,141	5.0	48.8	18.3	27.9
기타공공, 수리 및 개인서비스업	38.4	4.6	48.3	1,181	4.6	52.0	14.3	29.2
2003년 (전산업)	36.5	3.3	50.3	1,156	11.3	52.5	17.7	18.5
2002년 (전산업)	35.7	3.0	51.0	1,093	11.6	53.5	16.9	17.9
2001년 (전산업)	35.6	2.9	50.3	1,013	12.4	55.3	16.1	16.3

주 : 월급여액은 정액급여 및 초과급여 기준으로 연간특별급여액이 제외된 금액임

8. 임금계층별 근로자 분포

○ 임금계층별 근로자 분포를 살펴보면 400천원미만 임금계층의 근로자 구성비는 0.4%로 전년의 0.6%에 비해 소폭 감소

- 남자근로자는 1,200~1,600천원미만 임금계층의 근로자가 전체 근로자의

28.5%로 가장 많은 비중을 차지하는 반면,

- 여자근로자는 남자보다 다소 낮은 1,000~1,200천원미만 임금계층에 전체 근로자의 21.5%가 속해 있음

(단위 : %)

구성비 / 임금계층	2004			2003			2002			2001		
	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자	계	남자	여자
총 수	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
400천원미만	0.4	0.1	0.7	0.6	0.3	0.9	1.0	0.6	1.4	0.7	0.3	1.2
400 ~ 500	1.1	0.2	1.9	1.2	0.4	2.0	1.3	0.6	2.0	1.6	0.7	2.6
500 ~ 600	2.5	1.3	3.6	3.0	1.5	4.4	3.2	1.3	5.2	4.0	1.8	6.4
600 ~ 700	5.3	2.5	8.1	6.8	2.5	11.2	6.4	2.8	10.0	9.5	4.1	15.3
700 ~ 800	7.5	4.0	11.2	9.2	4.7	13.9	9.5	4.7	14.4	12.0	6.4	18.0
800 ~ 900	10.6	6.4	14.9	10.3	6.0	14.7	12.0	7.9	16.3	14.1	10.2	18.3
900~1,000	8.7	6.2	11.3	10.3	7.8	12.8	9.1	6.9	11.5	9.6	7.9	11.5
1,000~1,200	19.2	16.9	21.5	17.1	16.4	17.9	19.4	18.9	19.8	17.9	20.9	14.8
1,200~1,600	23.6	28.5	18.5	22.9	29.3	16.1	21.9	29.6	14.0	18.4	27.5	8.5
1,600~2,000	10.4	16.1	4.5	10.0	16.1	3.7	8.7	14.1	3.2	6.6	10.8	2.1
2,000~3,000	8.3	13.3	3.1	7.0	11.8	2.0	6.1	10.2	1.9	4.6	7.8	1.2
3,000천원이상	2.5	4.5	0.5	1.8	3.1	0.4	1.4	2.5	0.3	1.0	1.8	0.2

* 주 : 임금계층 구분은 임금총액 기준으로 하였으며 정액 및 초과급여액에 전년도 월평균 특별급여액 (전년도 연간특별급여액÷12월)을 포함한 금액임

IV. 외국에서의 개별적 근로관계법의 적용범위

1. 미국의 공정근로기준법(Fair Labor Standards Act)과 그 적용범위

1) FLSA의 주요내용

연방의회는 1938년 전국산업부흥법이 위헌판결을 받은이래 현안으로 되어 온 근로조건 기준에 관하여 공정근로기준법(Fair Labor Standards Act)을 제정하였다.

이 법률은 그때까지의 근로조건에 관한 법규제를 집대성한 것으로, 집단적 노사관계법의 일반법이라 할 수 있는 1935년의 전국노사관계법(National Labor Relations Act(NLRA). 일명 Wagner법)과 함께 미국 노동법의 주요 法源이라 할 수 있다.

이 법은 연방법이기 때문에 주법이나 공정경쟁규약에 의한 규제와 달리 전국 일률의 강행적인 기준을 설정하고 있고, 이에 위반할 경우에는 벌칙이 가해질 뿐만 아니라 생산된 제품의 洲外出荷가 금지된다. 이와 같은 공정근로기준법에 관해서 연방최고재는 1941년의 Darby사건에서 전원일치로 합헌성을 인정하였다.

공정근로기준법의 주요 내용으로, 최저임금제와 (제6조) 주40시간 법정근로시간 및 1.5배의 가산임금제(제7조) 및 16세의 최저연령제와 18세 미만자의 연소자보호제(제12조)를 들 수 있다. 1963년에 제6조(d)에 동일임금법(Equal Pay Act−EPA)이 추가되었다.

제6조 a)항에서는, 통상 또는 통상을 위한 상품생산에 종사하거나(뒤에서 보는 바의 '개인적용'의 문제) 통상 또는 통상을 위한 상품생산에 종사하는 기업(뒤에서 보는 바의 '기업적용'의 문제)의 근로자에 대해서는(이하 근로자라 칭한다) 시간당 5.15달러 이상의 임금을 지급하도록 할 것을 의무화하고 있다. 최저금액 금액은 FLSA 자체가 정하고 있고, 변경하는 경우에는 법률의 개정이 필요하다.

시간당 5.15달러[13] 이상으로 지급되는 한, 임금의 결정방법은 자유이고 주급제· 월급제· 성과급제라도 상관없다. 다만, 최저임금을 지키고 있는지의 여부는 노동주(workweek)를 단위로 하여 판단한다. 따라서 특정주에 최저임금을 하회한 부분을 다른 주의 상회한 부분으로 매꾸는 것은 가능하지 않다. 최저임금과 관련하여 도제·견습공 및 훈련기간 중의 근로자에 대해 특칙이 적용된다

제7조 (a)(1)에서는 근로자에 대하여 통상의 임금률(regular rate)의 1.5배 이상으로 지급하지 않고 1 노동주에 40시간을 초과하여 사용할 수 없다는 취지를 규정하고 있다. 결국, 주40시간을 넘는 근로에 대해서는 통상임금의 50%의 가산임금을 지급하게 함으로써 사용자로 하여금 법정근로시간을 준수하게끔 간접적으로 강제하고 있다고

13) 1997년의 개정에서 정해진 것이다

할 수 있다.

FLSA상의 최장시간규제는 이것이 전부이다. 따라서 1.5배의 시간외임금이 지급되면 법규정상으로는 여하한 장시간 근로도 가능하고, 협정의 체결이나 행정관청의 허가·신고 등의 절차도 필요하지 않다. 시간규제는 최저임금제와 마찬가지로 근로주를 단위로 한다. 주에 50시간 사용한다면, 10시간분은 시간외임금을 지급할 필요가 있고, 다음주가 30시간이였으므로 평균하여 주40시간으로 하는 것은 가능하지 않다. 예외로서 단체협약에 의해 일정한 요건의 하에서 26주간 단위 또는 52주 단위로 변형근로가 인정되고 있다(7조(b)(1), (b)(2)참조).[14] 또한 병원이나 간호시설에 있어 특례를 인정하고 있다(7조 (j)[15]).

공정기준법서는 연소자에 관하여 '가혹한' 연소자노동(opressive child labor)라는 개념을 사용하고 있다. 제12 (c)에서는 통상 또는 통상을 위한 상품의 생산 종사하는 기업에 있어서 사용자는 가혹한 소년노동을 사용하여서는 안된다고 규정하고 있고 12(a)에서는 가혹한 연소자노동이 행해진 사업장으로부터 출하된 상품에 관하여 통상을 금지하고 있다.

가혹한 연소자노동에 관해서는 동법 제 3(l)에 규정하고 있는데, 이에 따르면 1) 최저연령인 만 16세에 달하지 않은 자를 사용하는 경우 또는 2)16세 이상 18세 미만의 자를 노동부장관의 정한 유해위험작업(폭발물제조, 자동차운전, 석탄 등의 채굴, 벌목·製材, 도살·식품가공 등)에 사용하는 경우를 말한다[16].

---

14) 7조 (b) 어느 특정 근무일에 12시간을 초과하거나 특정 근무 주에 56시간을 초과하여 근무한 근로자가 그러한 초과 근무에 대해 통상적 임금 요율의 1.5배 이상의 보상을 받는 조건하에서, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는, 사용자가 위 (a)항에 명시된 근로 시간을 초과하여 고용하고, 동 항에 정해진 초과 근무 수당을 지급하지 않더라도 동 항을 위반한 것으로 간주하지 아니한다.

*(1) 중앙노동위원회(National Labor Relation Board; NLRB)가 인정하는 근로자 대표자들과 단체교섭에 의해 체결된 협약이, 어떠한 근로자도 연속 26주 동안 1,0404시간을 초과하여 고용되어서는 안된다고 규정하고, 동 협약에 따라 근로자가 고용되는 경우

*(2) 중앙노동위원회(NLRB)가 인정하는 근로자 대표자들과의 단체교섭에 의해 체결된 협약이, 연속 52주 동안 근로 시간이 절대상한선인 2,240시간을 초과하지 않으면서 최저 1,840시간(또는 적어도 46주 이상 동안 통상 주당 근로 시간이 적용되나 주당 30시간 이상) 최대 2,080시간의 고용이 보장되고, 동 기간 중의 모든 근무 시간에 대해 단체 협약상 규정된 임금 요율 이상으로 보수를 지급받으며, 또한 위 (a)항에 명시된 최대 주당 근로시간 또는 52주 동안 2,080시간을 초과한 근로 시간에 대해서는 통상 임금 요율의 1.5배 이상이 적용된다고 규정하는 경우, 동 단체협약에 따라 고용된 경우

15) (j) 병원과, 주로 환자, 노인, 정신적 질병 및 결함이 있는 자가 기거하는 시설을 경영하는 사용자는, 업무 개시 전에 사용자와 근로자간의 계약 및 양해에 따라 초과근무 수당 계산의 기준 기간을 연속 7일 대신에 연속 14일의 기간으로 인정하고, 동 기간동안 1일 8시간, 총 80시간을 초과한 근로에 대해 당해 근로자가 통상 임금 요율의 1.5배 이상을 지급 받는다면, 이 조 (a)항을 위반한 것으로 보지 아니한다.

16) "가혹한 아동노동(oppressive child labor)"은, 다음의 고용 조건을 가르킨다:

(1) 16세 미만의 근로자가 어떤 직종에 사용자에 의해 고용되어 있는 상태(단, 제조업과 광업, 또는 노동성 장관이 16-18세의 연소자에게 특히 유해하거나 이들 연소자의 건강과 복지에 해롭다고 판단한 업종이 아니라면, 부모 또는 친권자가 자녀 또는 보호 아동을 고용하는 경우에는, 16세 미만의

여기에는 일정한 예외가 인정되고 있는데 14세 이상 16세 미만의 연소자에 대해서 노동부장관이 정하는 조건의 범위 내에서 취로가 허용되는 경우도 있으며 농업, 영화·연극 등의 어린이역, 신문배달 등에 있어 최저연령의 예외가 인정되고 있다

2) 공정근로기준법(FLSA)의 적용범위

FLSA는 합중국헌법의 통상조항(제1조 제8절 제3항)에 의거하여 제정된 법률이고 그 적용범위에는 「개인적용」(individual coverage)과 「기업적용」(enterprise coverage)이라는 2개의 종류가 있다(제6조(a), 제7조(a)(1), 제12조(c)).

가. 개인적용

개인적용에 포함되는 것은 「통상(commerce)에 종사하는 근로자」 및 「통상을 위한 상품의 생산에 종사하는 근로자」이다. 요컨대 각 근로자마다에게 당해 勞動週에서의 일의 내용이 상기에 해당하는가 아닌가를 판단2하는 것이다. 「통상」이란 洲間通商 또는 외국과의 통상을 의미한다(제3조(b))[17].

여기서 미국법상의 근로자 개념에 유의하여야 한다.

공정기준법 제3조(e)(1)에서는 「이 법에서 근로자라 함은 아래의 (2)와 (3) 및 (4)에서 규정하고 있는 경우를 제외하고는 사용자에 의하여 고용되어 있는 모든 자를 말한다」고 하고 있다. 동 규정의 (2)와 (3) 및 (4)에서는 군무원, 일정한 범위의 입법·사법·행정공무원, 우편공무원과 가사농업에 종사하는 근로자 및 공공기관에서 자원해서 노무를 제공하는 자를 이 법의 적용대상에서 제외한다는 취지의 규정을 두고 있다.

미국법상 근로자개념의 특징으로 들 수 있는 것은 다음과 같다:[18]

① 통일적인 개념으로서가 아니라 특정한 법률의 적용대상 획정기준의 문제로서 접근하는 개별법적 접근태도를 취한다.

연소자라고 해도 '가혹한 아동 노동'에 해당하지 아니한다.)(1949년 개정 공정근로기준법 제3조 (c)항에 의해 개정됨)

(2) 16-18세의 근로자일지라도, 노동장관(1946년 정부 직제개편 계획 제2호에 의해, 최초 수립된 아동국장 및 아동국의 기능이 노동장관에게 이관됨)이 해당 연령 연소자에게 특히 유해하거나 건강과 복지에 위해하다고 인정하여 명령에 명시한 직종에 16-18세의 연소자를 고용한 경우.

단, 사용자가 노동장관의 규정에 의거하여, 당해 근로자가 가혹한 아동노동 연령을 초과했음을 인정하는 유효한 증명서를 보유하고 있는 경우에는 가혹한 아동노동의 경우로 간주하지 아니한다. 노동장관은, 제조업과 광업을 제외한 여타 업종에 있어서 14-16세의 연소자를 고용하는 경우, 그러한 고용이 그들의 건강과 복지에 해롭지 않은 조건으로 고용되었다고 노동장관이 인정하는 경우에는 가혹한 아동노동에 해당하지 않음을 규정 또는 명령으로 명시하여야 한다.

17) 제3조 (b) "'통상'(Commerce)이라 함은 주와 주 또는 어떠한 주와 외국과의 사이의 무역(trade), 통상(commerce), 운송(trasportation), 전송(transmission), 통신(communication)을 의미한다.

18) 이하의 내용은 강성태, 근로자의 개념, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 1994를 참조

② 근로자에 대한 제정법상 정의가 각 법률의 적용범위를 한정하기 위한 방식으로 규정된다. 예를 들어 공정근로기준법상 '근로자'는 보호대상에서 정부관련근로자, 가사농업근로자, 주 정부 관련 자원봉사자를 제외하기 위한 방식으로 정의된다.

③ 각 법률상 근로자 개념을 정함에 있어서 가장 우선적으로 고려되는 것은 당해 특정법률의 정책목표 내지 입법목적이다.

근로자개념과 관련하여 사용자-근로자 관계상 논란이 되는 것은 사용자와 독립계약자(independent contractor)의 관계이다. 독립계약자들은 고용계약이나 단체교섭관계를 규율하는 많은 제정법규의 적용대상에서 제외되는데 일반적인 구별기준은 맡겨진 일을 수행함에 있어 가지는 자율성의 정도이다. 그러나 그 실정법적 구별은 그 입법의 정책목표를 어떻게 인식하는가에 따라 달라진다.

이 문제 판단은 현실에 존재하는 다수의 실제적 사실들로부터 하였고 이를 총칭하는 기준을 흔히 '경제적 실체기준(economic reality test)'이라고 한다. 계약상 명칭이나 당사자의 표현된 의사와 같은 형식적 요소보다는 노무공급관계의 실질에서 근로자성을 구하는 이른바 '경제적 실체기준'에서 법원들이 자주 고려하는 요소는 ① 문제가 된 노무공급이 사용자의 사업에 통합되어 있는지의 여부 ② 관련된 시설과 장비등에 대한 관련 노무공급자의 투자정도 ③ 사용자가 노무공급자에 대해서 보유하고 있거나 행사하고 있는 지휘감독의 성질과 정도 ④ 노무공급자가 자신의 경영적 기술에 의존하는 이익과 손실에대한 기회를 가지는가의 여부 ⑤ 노무공급자에게 요구되는 기술이나 훈련 ⑥ 노무공급자와 노무이용자 사이의 관계의 계속성 등이다.

나. 기업적용

기업적용은 1961년의 법개정에서 도입된 것이고 통상 또는 통상을 위한 상품의 생산에 종사하는 「기업」의 근로자라면 각자의 일의 내용이 무엇인가를 불문하고 일괄하여 FLSA의 적용을 받는다. 이것에 의하여 FLSA의 적용범위는 비약적으로 넓어졌다. 「통상 또는 통상을 위한 상품의 생산에 종사하는 기업」의 기준은 ① 통상에 관련하는 피용자를 2인이상 사용하고 ②연간 매상·거래총액이 50만달러 이상이라는 요건을 충족하는 것이다(제3조(s)다만 병원, 간호시설, 학교에 관해서는 ① ②의 요건에 관계없이 FLSA의 적용을 받는다. 또 연방정부 및 주·지방정부도 「공공기관」(public agency)으로서 모두 FLSA의 기업적용의 대상으로 되고 있다.[19]

---

19) 제3조 (s)는 다음과 같다:
(1) '통상 또는 통상을 위한 상품 생산에 종사하는 기업'이라 함은 다음과 같은 기업을 말한다.
(A) (i) 통상에 종사하거나 통상을 위한 상품생산에 종사하는 근로자들을 고용하는 기업 내지는 어떠한 자(person)에 의한 통상을 위해 생산되거나 이동되어온 상품이나 재료에 대한 처리, 판매, 그밖의 작업을 하는 근로자들을 고용하는 기업
(ii) 연간 총매출액 또는 거래 총액이 50만달러 이상인 기업
(B) 병원, 주로 환자, 노인, 정신질환자, 심신장애자의 보호에 종사하는 기관, 정신적 또는 육체적 장애아를 위한

다. 적용제외

미국법에서는 위에서 살펴보는 바와 같이 기업적용과 개인적용의 이원적 접근방식을 취하면서도 근로자가 행하는 업무의 성질이나 내용 등에 따라서 구체적으로 적용범위의 예외를 규정하고 있다.

예를 들면 FLSA 13조(a)에서는 제 6조의 최저임금과 제 7조의 근로시간 규정이 적용되지 않는 경우를 열거하고 있고, 동조 (b)에서는 근로시간 규정이 적용되지 않는 경우를, 동조 (c)에서는 연소자노동의 예외규정을 광범위하게 열거하고 있다. 이 외에도 신문배달과 화환제작, 일정한 영토에서의 예외적용에 관하여도 매우 상세하게 규정하고 있는 것이 특징이다.

이들 중 동조(a)(1)의 관리직, 운영직, 전문직 근로자 및 외근판매원에 대해서 예외를 설정하고 있는 점이 눈에 띈다. 관리·운영직에 중사하는 상급직근로자에 관한 구체적 기준은 노동부장관이 정한 규칙에 따르는데, 이 경우 직무내용과 임금수준 등을 참고로 한다. 대체로 여기에 포함될려면, 직무수행상 독립적인 재량권을 가지고 있어야 하고 근무하지 않는 시간에 대하여 임금삭감을 받지 않는다는 점이 인정되어야 한다.

또 동조(b)의 근로시간 특례에서는 자동차운수, 철도, 항공 등 특별법의 규정에 따르는 것 외에도 농업관련 근로자, 영화관의 근로자, 택시 운전수, 입주한 가사사용인 등 상당히 자세한 내용이 포함되어 있다.

2. 독일의 개별적 근로관계법과 그 적용범위

1) 독일의 개별적근로관계법의 주요내용

독일은 한국의 근로기준법이나 미국의 공정근로기준법과 같은 포괄적인 근로관계법규가 없고, 개별적인 근로관계의 체결과 그 내용에 관한 법리는 민법의 규정을 매개로 발전되어 왔다.

다만 근로시간, 유급휴가, 해고제한에 관한 몇 개의 단행법률[20]이 제정되어 있다.

근로시간에 관한 기본적인 사항은 1938년에 제정되고 그 후 수차에 걸쳐 개정된 근로시간법(Arbeitszeitgesetz)[21]에서 규율하고, 이 외에 영업법, 폐점시간법, 연소자보호

학교 또는 영재교육을 위한 학교, 유치원, 초등학교, 중등학교, 고등교육기관(그러한 병원, 기관, 학교의 공립, 사립여부나 영리, 비영리의 여부는 불문한다).

(C) 공공기관(public agency)의 업무를 수행하는 기업

20) 임금과 관련하여서는 통화지급의 원칙을 규정한 영업법의 규정 및 1994년에 제정된 '축제일 및 질병사고시의 임금지급에 관한 법'이 있다. 임금의 지급방법, 시기 등과 같은 기본적 사항은 종업원평의회와 사용자간의 경영협정에 의해서 정해진다

법에서 도 근로시간에 관한 규정을 두고 있다.

근로시간법 제 3조에서는 1일 8시간, 1주 6일의 최장근로시간을 규정하고 6개월 또는 24주 단위의 변형근로를 허용하고 있다. 법정근로시간을 초과한 노동에 대해서는 가산임금을 지급하도록 하고 있다(동법 제 15조)[22]

영업법 제105b조에서는 일요일이나 국가가 승인한 축제일의 근로를 엄격히 제한하고 있고[23] 다만 수도·전기·가스공급사업이나 식품점 또는 교통사업 등에 있어서는 예외가 인정된다.

법정책적으로는 다소 논란이 있지만 폐점시간법에서는 근로자의 보호를 위하여 가게나 구매소 등에 대하여 평일에는 오후 6시 30분부터 익일 오전 7시까지 토요일에는 오후 2시 30분부터 영업을 하지 못하게 하고 있다.

18세 미만의 연소근로자에 대해서는 오후 8시 이후의 야간근로를 시키지 못한다(연소자보호법 제 9조 참조)

유급휴가의 보장에 관해서는 1963년에 제정되고 그후 수차례 개정된 연방연차휴가법(Bundesurlaubgesetz)에 따른다. 이외에도 경영조직법이나 연방육아수당법에서 교육휴가와 육아휴가를 각각 인정한다.

동법에 따르면 일반근로자 및 유사근로자[24]들은 최소 18일의 연차휴가권을 가진다(동법 제 1조, 2조 참조). 여기에는 몇가지의 특례가 있는데, 연소자들에 대해서는 25일 내지 30일의 연차휴가청구권이 인정되고(연소근로자보호법 제 19조) 중장해자에 대해서는 5일의 휴가가 추가된다(연방연차휴가법 제 47조). 연차휴가는 이를 유급으로 보장해주도록 하고 있다(동법 제 13조).

휴가청구권은 6개월간의 근로계약관계가 존속된 경우에 인정된다(동법 제 4조 및 제 5조 참조). 따라서 요양기간과 같이 실제 근로를 제공하지 않더라도 근로관계가 유지되면 이에 대하여 휴가를 부여하여야 한다. 6개월의 대기기간이 만료되기 전에 근로관계가 종료된 경우에는 매달마다 년차휴가의 12분의 1의 휴가청구권이 인정된다. 반일의 휴가청구권은 1일의 휴가청구권으로 인정해준다.[25]

경영조직법 제 37조 6항, 7항에서는 사업장평의회의 근로자대표위원에 대하여 일정한 법위에서 교육훈련휴가권을 부여하도록 하고 있다. 이 외에도 주법에서 일반근로자에 대하여 년 5일의 교육휴가를 부여하는 경우가 있다.

---

21) 가장 최근의 개정은 1994년에 행해졌는데, 동개정에서는 일요일과 축제일의 근로에 대한 종전의 규제가 완화되었고, 여성근로자의 야간근로제한도 삭제되는 등 노동의 유연성을 높이는 방향으로 약간의 개정이 있었지만, 기본적 원칙에는 변함이 없다.

22) 구법에서는 가산율을 25%로 명시하였으나 개정법에서는 이를 삭제하여 노사간의 단체협약이나 경영협정을 통하여 자율적으로 결정하도록 하였다

23) 이는 우리의 유급휴일이 일요일에 특정될 필요가 없는 것과 대비된다. 참고로 독일기본법 제 139조에서는 일요일과 축제일에는 휴식을 취할 수 있도록 법적으로 이를 보장하여야 한다는 취지를 규정하고 있다.

24) 이는 독일법상 특유한 개념으로 이에 관해서는 후술

25) 예컨대 1개월간 근무한 자는 2일의 휴가청구권이 부여됨. 이러한 독일의 계산법은 우리와 같은 월차휴가가 없기 때문에 기술적으로 도입한 것이다

육아휴가수당법에서는 육아수당을 받는 친권자가 3년간에 걸쳐 육아휴가청구권을 가질 수 있게 하고 이 기간 동안에는 해고제한의 보호를 받는다.

해고와 관련하여서는 민법 및 1951년에 제정되고 그 후 수차례의 개정을 거친 해고제한법(Kündigungschutzgesetz)이 적용된다. 또한 종업원평의회의 사전협의를 규정한 경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz)도 주요한 법원이다. 이 외에도 모성보호법과 장애자보호법에서 일정한 예외규정[26]을 두고 있다.

독일법에서 해고로부터 근로자를 보호하기 위하여 가장 먼저 채택된 방법이 해지기간(해약예고기간)의 설정이다.

통상적인 해고의 경우 일정한 해고기간이 필요한 바, 이에 관해서는 민법 제 622조에서 규정하고 있다. 근속년수에 따라 예고기간에 차등을 두는 것이 특징이다[27].

즉 2년 근무한 자에 대해서는 최소 1개월, 5년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 2개월, 8년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 3개월, 10년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 4개월, 12년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 5개월, 15년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 6개월, 20년 이상 근무한 자에 대해서는 최소 7개월의 해지기간이 필요하다.

통상적인 해고와는 달리 해고예고가 필요하지 않은, 이른바 "즉시해고"도 예외적으로 인정되고 있다. 즉 민법 제626에서는 제반상황이나 양당사자의 이해관계를 고려해 볼 때 해고예고기간을 지키도록 하는 것이 현저히 불합리하다고 여겨지는 경우에는 바로 해고를 할 수 있도록 하고 있다.

해고제한법에서는 해고의 정당사유 등의 규정을 통하여 해고근로자를 보호하고자 하고 있다. 특히 종업원 평의회의 위원에 대해서는 즉시해고를 할 만한 중대한 사유가 있을 경우에만 해고를 할 수 있도록 하고 있다(동법 제 15조 참조)

과거에는 독일에서도 영미국가와 같이 사용자의 해고의 자유가 법적으로 보장되었으나(해고의 적법성 추정), 1951년에 이법이 제정됨으로써 정당한 이유가 없는 경우에는 해고를 할 수가 없게 되었다(해고의 위법성 추정[28]). 해고제한법에서는 해고이 정당사유로 일신상의 사유, 행태상의 사유, 긴박한 경영상의 필요성을 들고(동법 제 1조) 있고, 긴박한 경영상의 필요성에 기한 해고에 대해서는 행정관청에의 사전신고를 요구하고 있다(동법 제 제 17조 이하 참조).

경영조직법 제 102조 1항에서는 사용자가 근로자를 해고하고자 할 때에는 반드시 종업원평의회의 사전 협의를 거치도록 하고 있다. 사용자의 협의의무는 즉시해고이든 통상해고이든 이를 묻지 않고[29] 요구된다. 종업원평의회와의 협의를 사전에 거치지 않

---

26) 모성보호법에서는 임신기간 중 및 출산 후의 4주 까지 해고를 시키지 못하도록 하고 있고 장애자보호법에서는 장애자를 해고할 때에는 행정관청의 승인을 받도록 하고 있다

27) 구법에서는 사무직 근로자와 육체근로자를 구분하여 예고기간에 차 등을 두었으나 위헌판정을 받았다. 연방헌법재판소, 1982.11.16 판결

28) Weiss, 앞의 책, 84면 이하

29) 즉시해고의 경우에는 종업원평의회가 사용자로부터 해고의 통지를 받은 날로부터 3 일 이내에 문서로 찬부를

고 행한 해고는 그 자체로 무효이다. 사용자는 종업원평의회와의 협의절차를 거치기만 하면 되고, 종업원평의회가 이를 찬성하거나 거부하는가는 당해 해고의 법률적 효과에는 영향을 미치지 못한다. 그러나 종업원평의회가 이를 거부하였다는 사실은 향후 노동법원에서 해고의 정당사유를 다툴 때 유리한 증거로 작용된다.[30]

2) 적용범위

가. 근로자 개념

위에서 살펴본 바와 같이 미국에서는 근로자 개념을 개별법적으로 접근하여 각 입법의 취지에 입각하여 근로자 개념을 합목적적으로 설정하고 있는데 반하여, 독일에서는 근로자에 관한 실정법적 정의를 내리지 않다는 점이 그 특징이라 할 수 있다.[31]

따라서 근로자개념에 관해서는 학설이나 판례에 맡겨져 있는데, 대체로 '종속노동론' 내지 '노동의 종속성 이론'에 의해 근로자 개념에 접근하고 있다.

통설적 견해에 따르면 근로자성의 요건은 다음과 같다:

첫째, 근로자는 근로제공의 의무를 진다. 여기서의 노동은 욕구를 만족시키는 모든 행위로서 경제생활에 있어서 노동으로서 가치가 있는 것을 말한다.

둘째, 노동급부 이행에 관한 의무는 '사법상의 계약이나 이와 유사한 관계'에 기초한 것이어야 한다. 따라서 공무원은 공법상의 임용계약에 따라 노무를 제공하므로 근로자로 보지 아니한다. 囚人과 敎護소년의 경우에도 노무급부의 기초가 공법상의 제규정(소년재판소법 제9조3항, 소년복지법 제64조이하)에 있기 때문이다.

셋째, 근로자가 제공하는 근로는 그 방법과 시간배정 등에 있어 타율적으로 결정된다. 이를 통상 '인적 종속성'이라 칭한다.

위의 요건 중 인적종속성은 경제적 종속성에 대비되는 개념으로 현재 판례법상 유용한 기준으로 자리잡고 있지만, 그 내용이 무엇인지에 관해서는 일의적으로 이를 설명할 수 없기 때문에 그 해석을 둘러싼 다툼이 발생하곤 하였다

그 중 1960년 초반 병원 원장의 근로자성 여부, 1970년 중반 방송업에서의 자유공동작업자(저널리스트, 음악가 등)의 근로자성 여부에 관한 다툼이 대표적인 사례이다. 연방노동법원은 위 두 사건에서 모두 근로자성을 인정하였는 바, 이는 법원의 태도가 보호필요성의 관점에 입각해 인적종속성의 결정적 징표라 할 수 있는 타인결정성의 의

표시하여야 하고 통상해고의 경우에는 1주일 이내에 문서 로 찬부를 표시하면 된다. 종업원평의회의 회신이 없으면 해고에 동의한 것으로 법 률상 추정된다

30) 자세한 내용은 Weiss, 앞의 책, 87면 이하 참조

31) 영업법 제 84조에서는 근로자이 반대개념이라 할 수 있는 독립영업자에 관해 규정하고 있는데 , 여기에서는 독립영업자를 " 기본적 부분에 있어 자기의 활동을 자유로이 결정할 수 있고 근로시간을 자신이 결정할 수 있는 자"를 의미한다.

또한 단체협약법 제12a조에서는 유사근로자 개념을 설정하고 있다(이에 대해서는 후술).

미를 완화하여 근로자의 인정범위를 넓혀가고 있는 것이라고 평가할 수 있다.[32]

근로자와 독립영업자의 중간영역에 있는 '유사근로자' 개념이 입법적으로 도입되어 있다. 유사근로자란 한편으로 인적종속성의 정도가 낮거나 인적종속성이 존재하지 않아 근로자로 볼 수 없고 또다른 한편으로 경제적으로 종속되어 있어 독립영업자로 보기도 어려운 자를 말한다.

유사근로자의 관념은 판례를 통해 형성되어오다가 1974년에 단체협약법에 신설된 제 12a조에서 이를 보다 구체화시켰다.

단체협약법 제12a조에 따르면 유사근로자란 경제적으로 종속되어 근로자와 비교해 볼 때 사회적 보호를 할 필요가 있는 자로서 다음의 요건을 충족하는 자를 말한다;

첫째, 고용계약 또는 도급계약에 기하여 타인을 위하여 활동하며 채무적 급부를 원칙적으로 스스로, 근로자의 협력없이 제공하여야 할 것

둘째, 자신의 노무가 주로 1인 또는 하나의 그룹을 위하여 제공되고, 그로 인한 보수가 자신의 총수입의 평균 50%[33] 이상을 차지할 것

유사근로자들은 원칙적으로 노동법이 적용되지 않지만 이들에 대하여는 독립영업자에 비하여 몇몇 노동법상의 보호가 행해진다. 예를들면 유사근로자와 계약상대방과의 분쟁은 노동법원의 관할에 속하고(노동법원법 제5조) 근로자와 동일하게 연차유급휴가청구권이 인정되며(연방연차휴가법 제2조2호), 그들의 근로조건에 관하여 단체협약을 체결할 수 있다(단체협약법 노동협약법 제12a조).[34]

유사근로자의 특별유형으로 가내근로자를 들 수 있는데 이들에 대해서는 가내노동법(Heimarbeitsgesetz)이 적용된다.

동법에 의하면, 가내근로자란 혼자서 또는 가족 구성원의 도움을 받아 자신이 스스로 선택한 장소에서 – 그것이 아파트이든 단독주택이든 기타 일정한 장소이든 문제가 되지 않는다.– 타인을 위해서 노동하고, 노동결과의 사용을 당해타인에게 맡기는 자를 말한다.

동법은 2인 이내의 자(가족 구성원이 아닌 자)의 도움을 받아 자신이 스스로 선택한 장소에서 타인을 위해서 노동하고, 그 노동결과의 사용을 당해 타인에게 맡기는 자에게도 적용된다. 원료를 제공받았는지의 여부는 동법 적용상 차이가 없다. 이러한 가내근로자들 항시 유사근로자로 취급된다.

이에 반해서, 가내근로자가 비가족 구성원인 3인이상의 도움에 의존하거나 자신이 업무를 제 3자에게에게 위임하는 경우에는, 경제적 종속이 정도와 사회적인 보호의 필요성을 개별적으로 심사하여 유사근로자 여부를 판단한다.[35]

---

32) Weiss, labor law and industrial relations in the Federal Republic of Germany, Kluwer, 1987, 40면

33) 예술적, 문화적, 언론직에 종사하는 자는 1인으로부터 받은 보수가 자신의 총수입의 3분의 1 이상을 차지할 때에는 유사근로자로 본다(단체협약법 제12a조 3항). 상사대 리인의 경우에는 계약상 1인을 위하여 노무를 제공하거나 사실상 1인을 위하여 노무 를 제공하고 6개월의 보수총액이 2000마르크에 미치지 못한 경우에 유사근로자로 인 정된다(시행령에 규정됨, Weiss, 앞의책, 41-42면 참조).

34) 다만 위의 상사대리인에 대해서는 단체협약의 체결을 인정하고 있지 않다(단체협약 법 제12a조 4항)

가내근로자는 여타의 유사근로자에 비해 가장 근로자에 가까운 보호를 받고 있는데 해고제한법, 근로시간법이 이들에게는 적용된다

근로자를 '생산직근로자'(Arbeiter)와 '사무직근로자'(Angestellte)로 구분하여 달리 취급하고 있다는 점도 독일 노동법의 큰 특징이라 할 수 있다.

예를들면, 사무직근로자들에 대해서는 생산직근로자보다 해약고지기간이 길며 (민법 622조, 위헌판정을 받은 바 있음), 질병으로 인한 임금계속지급에 관해서도 다른 법률에서 약간씩 다른 형태로 규정되고 있다(사무직근로자에 대해서는 영업법제 133c조, 상법 제63조 및 민법 제616조 2항에서, 생산직근로자에 대해서는 임금계속지불법이 규정). 특히 경영조직법, 공무원대표법 및 공동결정법에서는 생산직근로자와 사무직근로자의 구별을 조직원리의 기초로 삼고 있다. 사회보험의 적용에 있어서도 양자는 구별된다.

또한 관행상으로 양자가 분리취급되는 경우도 있다. 단체협약이 별도로 체결되기도 하고 사용자의 부가급여를 설정할 때에도 양자를 달리 취급한다

생산직근로자와 사무직근로자를 구분하는 전통은 입법정책적으로도 오래전부터 형성되어 왔다고 할 수 있다. 즉 1924년의 직원보험법제 3조1항(현재의 사회법전 6편 제 133조2항에 해당)에서 사무직근로자를 유형화하고 있고 이 기준은 현재에도 여전히 – 여타의 노동법규에도– 통용되고 있다. 이에 따르면 다음의 경우가 사무직근로자에 해당된다; .

(1) 관리적 지위에 있는자

(2) 사업장·사무소·관청에서의 기술직원, 직공장 및 이와 유사한 지위를 가지는 자

(3) 사무직원. 다만 사환이나 청소와 정리업무 및 이와 유사한 업무에 종사하는 자는 제외하지만 직장문서계는 포함

(4) 상업사용인 및 그밖의 상업적 업무에 종사하는 자. 약국의 도제 및 실습생

(5) 배우 및 음악가 (연기 또는 연주의 예술적 가치는 묻지 않는다).

(6) 교육, 교수, 원호, 간호, 복지업무에 종사하는 자

(7) 선장, 갑판작업 및 기관작업의 고급선원, 의사, 무선사, 회계사, 관리사, 관리조수 및 이와 유사한 지위를 가지는 자

(8) 민간항공기승무원.

결국, 상업적 업무와 사무적 업무에 종사하는 자는 대체로 사무직근로자에 해당되고 그밖의 업무에 있어서는 육체적 노동인가 정신적 노동인가에 따라 결정된다고 할 수 있다.

최근에 들어와 관리적 직원(leitende Angestellte)의 그룹이 달리 취급되고 있다. 예

35) 심사는 가내노동법에 의해 설치된 가내노동위원회에서 행해지는데 경제적 종속성의 지표로 거래총액, 보조자의 숫자, 투자자본의 량과 종류 등이 사용된다. 위의 책 42 면 참조

를들면, 관리적 직원에 대해서는 해고제한법의 특별규정이 적용되고(해고제한법제 14조2항참조), 관리적 직원은 공동결정법상의 감사회(Aufsichtsrat)[36] 참가에 있어 독자의 그룹을 형성하며(공동결정법 제 3조3항2호), 이들에 대해서는 경영조직법의 적용이 배제된다(경영조직법 제 5조3항). 1988년에 제정된 관리직대표위원회법에 의하여 관리직 직원은 별도의 대표위원회를 구성한다.

관리직 직원은 전체의 1.5%에 불과하지만 그들의 지위나 일반근로자와의 특별한 관계에서 독자적 취급이 요청된다. 관리직 직원의 개념에 관해서는 법률마다 조금씩 달리 사용하고 있다.[37]

3) 구체적 적용범위

가. 근로시간법

근로시간법은 이윤추구의 목적으로 운영되지 아니하더라도 모든 종류의 사업장과 행정관청에 고용된 18세 이상의 근로자[38]에게 적용된다. 유사근로자는 원칙적으로 적용되지 않지만 가내근로자에게는 적용된다.

근로시간법의 적용에 관해서는 사업 또는 사람에 따라서 일정한 예외를 설정하고 있다.

우선 다음 각호에 사업에 대하여서는 근로시간법이 적용되지 아니 한다(근로시간법 제1조 1항);

① 원예, 포도재배, 양봉, 임업, 수렵, 가축사육 등을 포함하는 농업과 개인적 필요에 의하여서만 수행되는 私的성질의 부수적 농업활동과 임업활동

② 어업, 해운업, 항공업

또한 다음과 같은 자들에게는 근로시간법이 적용되지 아니 한다(동조 2항);

① 성명이 상업등록부 또는 협동조합단체등록부에 등록되어 있는 업무수행의 일반적 대리권한과 대표권한을 지니는 자

② 최소한 20인의 근로자의 작업을 감독하거나 사회보험법상 강제적용대상이 아닌 고소득 관리직 근로자

③ 약사로서 교육받고 약국에서 근로하는 근로자

또한 제빵점(빵, 과자, 케이크류 제조점)과 제과점(캔디, 아이스크림, 케이크 등의 제조점) 및 간호사와 간호기관의 근로자에 대해서는 관련 특별법에 따라 규율된다(동

---

36) 독일의 감사회는 우리의 경우와 달리 일반적인 감사업무 외에도 전략적 경영방침을 결정하고 이사를 선임하는 권한을 갖는다

37) 자세한 내용은 Weiss, 앞의 책, 44면 이하 참조

38) 18세 미만의 연소근로자에 대해서는 연소근로자보호법이 적용된다

조 제 3항)

근로시간, 휴식시간(Ruhezeit)[39] 휴게시간[40]에 관한 3조에서 13조까지의 규정에 대해서도 적용상의 특례를 두고 있는 데 그 구체적 범위는 다음과 같다;

① 원료와 식료품의 부패를 방지하기 위하여 긴급하게 요구되는 임시적 근로의 경우(동법 제14조 1항 참조)

② 비교적 적은 수의 근로자가 업무에 종사하는 경우에 그들이 업무를 행하지 않게 되면 현저한 경제적 손실을 초래되고 사용자가 다른 조치를 취하는 것이 합리적으로 기대될 수 없는 경우(동조 2항 참조)

나. 연방연차휴가법

연방연차휴가법은 사무직근로자, 생산직 근로자 및 직업훈련을 받는 자에게 적용된다.

이 법은 유사근로자에게도 적용된다는 점이 특징이다.

다. 해고제한법

해고제한법은 민간, 공공부문을 불문하고 모든 근로자에게 적용된다(해고제한법 제23조 1항 1문).

법인의 대표를 제외한 관리직 업무에 종사하는 자에게도 적용된다는 점을 명시하고 있다(동법 제 14조 참조)

유사근로자에게는 적용되지 않는 것이 원칙이지만 가내근로자에게는 적용된다.

사업의 규모에 따라 적용예외를 설정하고 있는 점이 특징이다. 상시 5인 이하의 근로자를 사용하고 있는 사업장과 행정관청에는 적용상의 특례를 두고 있다. 이 경우 상시의 근로자수를 계산함에 있어서는 근로시간 수가 1주 10시간 또는 1개월 45시간을 초과하는 근로자만 포함하고 또한 직업훈련을 위하여 고용된 자는 그 계산에서 제외된다(동법 제 23조 참조)

3. 일본의 근로기준법과 그 적용범위

1) 근로기준법의 주요내용과 그 적용범위

주지하다시피 우리의 노동법제를 일본법을 계수하였기 때문에 노동법의 체계나 구

39) 12조에서 1일 근로 후 최소한 11시간의 휴식시간이 부여되어야 함을 규정하고 있다.
40) 6시간 이상 근로하는 경우 최소 30분의 휴게시간을 부여하여야 한다(제 12조 참조)

체적 내용에 있어 일본과 매우 유사하다.

근로기준법에 있어서도 사정은 마찬가지다. 따라서 본고에서는 우리법제와 차이가 나는 부분에 대해서만 간략하게 설명하기로 한다.

가. 임금

임금법제에 있어 우리와 대비되는 점은 일본에서는 퇴직금제도를 법정화하지 않고 임의적으로 설정하도록 한다는 점이다. 따라서 단체협약이나 취업규칙 등의 규정을 통하여 근로자의 중요한 귀책사유로 근로관계가 종료하였을 경우 퇴직금을 삭감하거나 퇴직금을 지급하지 않는 것도 가능하다. 그러나 퇴직금제도는 일본기업에 보편화되어 있고 퇴직연금제가 도입된 기업도 많다. 30인 이상의 사업장에서 퇴직금제도를 채용하고 있는 기업은 거의 90%, 100인 이상 규모 기업은 거의 100%이다. 또한 규모 10-29인의 소기업에서도 약 4분의 3에 이르는 기업이 퇴직금제도를 설정하고 있다.[41]

기업도산시의 임금채권의 확보를 위해, 우리와 같은 우선변제특권제도는 없고, "임금지급의 확보에 관한 법"을 통하여 규율하고 있다. 동법에서는 퇴직금 등의 체불임금이 있을 때에는 국가가 사업주를 대신하여 임금이 일정부분을 지급해 주도록 하고 있다.[42]

나. 근로시간

근로시간제도에 있어서는 우리와 매우 상이한 제도를 도입하고 있다. 임금수준이나 임금체계 등의 결정은 기본적으로 노사교섭에 맡겨지고 이와 관련한 법규는 최저기준으로서 기능하는데 반하여, 근로시간의 경우에는 그 제도의 구조, 기준 공히 법에 의한 규제의 정도가 강하고 이와 관련한 법규는 표준기준으로 기능하기 때문에 그 나라 독자의 노사관계의 실태를 반영하기 때문이다.

우리와 비교해보면, 법정근로시간 변형근로제와 플렉스타임제의 도입여부, 시간외근로의 요건과 가산율. 연차유급휴가의 성립요건과 일수에 있어 우리와 차이가 있다

즉 소정근로시간(시업시각부터 종업시각까지의 시간 빼기 휴식시간)은 1일 8시간, 1주 40시간이라는 법정근로시간을 초과하여서는 아니된다(근로기준법 제 32조 1항).

법정근로시간을 초과하여 시간외 근로를 시킬려면 과반수 종업원을 조직하는 노동조합 또는 과반수 종업원을 대표하는 자와의 서면협정을 체결하고, 이를 근로기준감독서에 신고하여야 하며(동법 제36조) 시간외 근로 등에 대해서는 25%의 가산임금을

41) 이하는 管野和夫, 雇用社會 法, 有斐閣, 1996. 의 책을 많이 참조하였음

42) 자세한 내용은 이철수, 노동관계법국제비교연구(I)- 정리해고, 임금보장제, 한국노동연구원, 1993, 157면 이하 참조

지급하여야 한다[43](동법 제37조).

법이 정한 변형근로시간제의 요건을 충족시키면(제32조의 2, 제 32조의 4 참조), 법정근로시간을 일정기간에 걸쳐 변형적으로 배분할 수가 있다. 시업·종업시각의 결정을 근로자에 위임하는 플렉스타임제도 일정한 요건 하에서 도입하고 있다(제32조의 3).

근속 6개월 이후 1년에 10일-20일의 연차유급휴가를 근속년수에 따라 부여하고 있다(제39조).

다. 근로시간의 단축

일본에서는 1988년 이래 근로시간이 크게 단축되었다. 1987년도에는 연간 총실근로시간은 2,120시간이었지만, 1993년에는 1,909시간으로 되고, 6년간에 211시간, 연평균 35.1시간으로 빠르게 단축이 진전되었다.

이러한 시간단축경향의 계기는 1987년 근로기준법 개정(1988년 4월부터 실시)에 있다. 동개정의 골자는 주법정근로시간은 '48시간'에서 '40시간'으로 대폭 단축하고, 이를 단계적으로 실시하는 것이다.

종래의 '8시간 근로의 원칙'은 1987년의 법개정을 통하여 ' 1주 40시간'의 원칙으로 수정되었지만, 그 당시에는 근로시간 단축의 목표를 선언하고자 하는 의미가 강하였다. 그 결과 부칙 제131조에 기한 政令(근로시간령 제1조)에 의하여 주 46시간제가 적용되었다(제1단계). 이어서 제2단계로서 1990년의 근로시간령의 개정을 통하여 1991년 4월부터 주 44시간으로 단축되었다. 그리고 제3단계로 1993년 근로기준법 개정을 통하여 1994년 4월부터 주 40시간제로 이행하게 되었다.

단 각 단계의 법정근로시간에 대하여는 중소영세기업에의 배려로서 그때마다 일정규모·업종의 사업에 대한 유예조치가 설정되었다. 제3단계에 대해서도 일부 규모·업종의 사업에 대하여는 3년간 주44시간제로 유예되어지고, 주40시간제는 1997년도 부터 산업 전체로 적용된다.

이와같이 주40시간제의 도입은 일본 산업계의 중층구조를 감안하여 규모와 업종에 따라 단계적으로 실시되고 있다.

단계별 실시 내역은 다음 표와 같다

<표> 일본의 업종별·규모별 근로시간

1. □ 원칙: 1주 40시간
2. ▨ 유예: 44시간(최대한 '97년 3월 31일까지)
3. ■ 특례: 1주 46시간

(주) 5인 미만에 대해서는 '95년 7월 31일까지 1주 48시간

---

43) 1993년 개정을 통하여 휴일근로에 대하여는 35%가 가산되도록 하고 있다.

4. ☒ 특례에 준하는 경과조치 '95년 3월 31일까지 1주 46시간

	301인 이상	101~300인	31~100인	10~30인	1~9인
제조업(1호)	40	44	44	44	46
광 업(2호)	44	44	44	44	46
건설업(3호)	40	44	44	44	46
운륜교통업(4호)	44	44	44	44	46
화물취급업(5호)	44	44	44	44	46
임 업(6호)	44	44	44	44	44
상 업(8호)	40	44	44	44	46 48
금융광고업(9호)	40	40	40	40	40
영화연극업(10호)	40	40	44	44	46
통 신 업(11호)	40	40	40	40	40
교육연구업(12호)	40	44	44	44	44
보건위생업(13호)	40	44	44	44	46
접객오락업(14호)	40	44	44	44	46 48
청소도축업(15호)	44	44	44	44	46
판공업(16호)	40	40	40	40	40
기타사업(17호)	40	40	44	44	44

* 자료: 일본 노동성 노동기준국 勞働時間에 관한 보고서, 1996

2) 근로기준법의 적용범위

가. 일반적 적용범위

일본 근로기준법 제8조에서는 근로기준법이 적용되는 사업 또는 사업장을 구체적으로 열거하고 있는 점이 우리와 대비된다. 다만, 적용예외 사유로서 우리와 마찬가지로 동거의 친족만을 사용하는 사업 또는 사업장 또는 가사사용인을 규정하고 있다.

적용사업 또는 사업장은 다음과 같다:

1. 물건의 제조, 개조, 가공, 수리, 세탁, 선별, 포장, 장식, 손질, 판매를 위한 준비, 파괴 혹은 해체 또는 재료의 변조의 사업(전기, 가스 또는 각종 동력의 발생, 변경 혹

은 전도의 사업 및 수도의 사업을 포함한다)

2. 광업, 石切業 그 밖에 토석 또는 광물채취의 사업

3. 토목, 건축 그 밖에 공작물의 건설, 개조, 보존, 수리, 변경, 파괴, 해체 또는 그 준비의 사업

4. 도로, 철도, 궤도, 索道, 선박 또는 항공기에 의한 여객 또는 화물의 운송의 사업

5. 도크, 선박, 岸壁, 波止場, 정차장 또는 창고에 있어서 화물의 취급의 사업

6. 토지의 경작 혹은 개간 또는 식물의 재식, 재배, 채취 또는 벌채의 사업 그 밖에 농림의 사업

7. 동물의 사육 또는 수산동식물의 체포 혹은 양식의 사업 그 밖에 축산, 양잠 또는 수산의 사업

8. 물품의 판매, 배급, 보관 혹은 임대 또는 이용의 사업

9. 금융, 보험, 매개, 주선, 集金, 안내 또는 광고의 사업

10. 영화의 제작 또는 영사, 연극 그 밖에 흥행의 사업

11. 우편 또는 전기통신의 사업

12. 교육, 연구 또는 조사의 사업

13. 병자 또는 허약자의 치료, 간호 그 밖에 보건위생의 사업

14. 여관, 요리점, 음식점, 접객업 또는 오락장의 사업

15. 소각, 청소 또는 도살의 사업

16. 앞의 각호에 해당하지 않는 관공서

17. 기타 명령에서 정하는 사업 또는 사업장

위의 제 8조는 근로기준법이 적용되는 「사업 또는 사업장」의 범위를 열거하는 형식으로 규정하고 있지만 거의 전산업을 망라하고 있다고 할 수 있다. 근로기준법이 근로자의 「인간다운 생활」을 영위하기 위해 필요한 근로조건의 최저기준을 정하는 것이므로, 모든 사업에 적용되는 것을 원칙으로 삼고 있다. 따라서, 본조의 취지는 근로기준법의 적용범위를 한정한 것이 아니라, 업종에 따라 근로시간규제 등, 근로기준법적용상의 취급을 달리 하는 경우(예를 들면 40조·41조 등)의 종별화를 정한 것으로 해석해야 할 것이다.

위의 제 17호의 「기타 명령으로 정하는 사업 또는 사업장」에는 현재 ①변호사·공인회계사·세리사 등의 자유업, ②파출부회, 속기사회 그 밖에 파출의 사업, ③법8조 1−15호의 사업에 해당하지 않는 법인 또는 단체의 사업·사무소 가 포함된다.

나. 특별법에 의한 적용제외

a. 선원

선원법의 적용을 받는 근로자에 대해서는 근로기준법 제 1조 내지 제11조(총칙규정), 제117조 내지 제119조 및 제 121조(총칙규정에 대응하는 벌칙)를 제외하고 근로기준법은 적용되지 않는다(선원법 제 6조 참조). 선원노동의 특수성을 감안한 것이라 할 수 있다.

b. 공무원

(a) 국가공무원

일반직의 국가공무원에 대해서는 근로기준법 제정 당초에는 전면적으로 적용되었지만, 1948년에 국가공무원법이 개정됨에 따라 적용되지 않게 되었다(국가공무원법 부칙 제16조).

다만, 특별히 법률이 제정되기까지의 사이에 국가공무원법 정신에 저촉되지 않고, 또 동법에 기인하여 법률 또는 인사원규칙에서 정해진 사항에 모순되지 않는 범위에서 근로기준법 및 동법에 기인한 명령이 준용되는 것으로 하였다.

특별직에 속하는 국가공무원(동법 제2조3항)에 대해서는 위의 부칙 제 16조가 적용되지 않는다. 따라서, 원칙적으로 근로기준법이 적용된다고 하겠으나 특별법에 의하여 법원직원, 국회직원, 자위대원 등에 대해서는 근로기준법이 적용되지 않는다.

또, 국영기업노동관계법의 적용을 받는 국영기업(우정, 국유임야, 인쇄, 조폐)에 근무하는 현업직원[44](국영기업노동관계법 제 2조)에 대해서는 근로기준법은 원칙적으로 적용되지만(동법 40조1항), 국가공무원법이나 인사원규칙에 의해서 근로기준법의 특례가 인정되고 있는 경우(예를 들면 재판으로서의 감급, 연차유급휴가의 절차 등)에는 이에 따른다.

(b) 지방공무원

일반직의 지방공무원에 대해서는 근로기준법은 일부를 제외하고 적용된다. 지방공무원법에 따라 이들에게 적용이 배제되는 규정과 그 이유를 보면 다음과 같다

우선 근로기준법 제 2조(근로조건의 노사대등결정), 제 32조의 3 내지 제 32조의 5 (플렉스타임제, 변형근로시간제), 제 38조의 2 제2항 내지 제5항(사업장외 근로 · 재량근로에 관한 간주근로시간제), 제 39조 5항(年休의 계획적 부여), 제 89조 내지 제93조(취업규칙)의 규정은 근무조건 조례결정의 원칙(지방공무원법 제24조6항)에 의

44) 현업직원은 공무원에 해당된다

해 적용이 배제된다

근로기준법 제 24조 1항(임금지급방법), 제 75조 내지 제 88조(재해보상)에 대해서는 특별규정(지방공무원법 제25조2항) 과 특별법(지방공무원재해보상법·1967년)이 적용됨에 따라, 근로기준법 제 102조(근로기준감독관의 직무권한)는 인사위원회 또는 지방공공단체의 장의 권한에 위임되기(지방공 무원법 제 58조4항) 때문에 적용이 배제된다

공립의무교육제학교 등의 교육직원에 대해서는 교육직원급여특별조치법(1971년)에 의하여 제 38조(할증임금) 규정이 적용되지 않고 동법 33조 3항(공무를 위하여 임시적으로 필요한 경우의 시간외 근로)의 적용 특례가 인정되고 있다.

또한 지방철도 · 수도 · 가스 사업 등 지방공공단체가 경영하는 지방공영기업(지방공영기업법 제 3조1항)의 직원에 대해서는 지방공무원재해보상법이 적용되기 때문에 근로기준법 제75조 내지 제88조가 적용되지 않고 이외에는 근로기준법이 적용된다.

단순한 노무에 고용되는 일반직의 지방공무원(지방공무원법 제57조)에 대해서도 동일하게 취급된다. 또한 특별직에 속하는 지방공무원(동법 제 3조3항)도 근로기준법상의 근로자에 속하는 한, 근로기준법의 적용을 받는다.

c. 가내노동법

일본경제의 저변을 지탱하는 존재이면서도 근로기준법의 적용을 받지 못하고 오랫동안 방치되어 온 가내근로자에 대하여 주로 최저공임과 안전위생의 면에서의 보호를 도모한다는 취지에서 가내노동법(1970년)이 제정되었다.

가내노동법의 정의에 의하면 가내근로자란 “물품의 제조·가공, 판매 또는 이들의 청부를 업으로 하는 자, 기타 이들의 행위에 유사한 행위를 업으로 하는 자 등으로부터 주로 노동의 대상을 얻기 위하여 그 업무의 목적물인 물품을 위탁받아 물품의 제조 또는 가공 등에 종사하는 자이며 그 업무에 대하여 동거하는 친족 이외의 자를 사용하지 아니하는 것을 常態로 하는 자”이다(동법 제 2조 2항). 행정해석은 이러한 정의에 관하여 동거하는 친족 이외의 자를 사용하지 아니하는 것을 常態로 하는 자가 종종 임시적으로 타인을 사용하더라도 가내근로자인 속성을 상실하는 것이 아니라고 본다.

동법의 주된 내용은 위탁자에 의한 가내근로대장의 교부, 기입의무, 주변지역에 있어서 동일 또는 유사한 업무에 종사하는 근로자의 근로시간을 넘지 않는 취업시간, 위탁중지의 예고, 통화불 · 전액불 · 1월 이내의 정기일불 등의 가내근로심의회의 조사심의의 결과를 존중하여 결정하는 최저공임, 안전위생에 관한 위탁자의 조치의무, 위탁자에 의한 신고 · 帳簿備付 · 신고 의무 등이 위반에 대한 벌칙의 적용과 함께 규정되어 있다. 또 가내근로자의 업종에 따라서는 노재보험의 특별가입이 인정된다.

본조 각호에 해당되지 않는 사업은 거의 없기 때문에 본법은 전사업에 대하여 적용되고 있다고 할 수 있다. 다만, 본법은 업종·업태에 따른 근로 태양의 차이에 의하여

특히 근로시간 등의 적용에 대해서 차이를 두고 있기 때문에 본조 각호에 업종을 열거하고 있는 것이다.

그러나, 본법의 적용이 제외되고, 다른 보호법규의 적용을 받는 경우도 있는데 첫째, 선원법에 의한 선원에 관해서는 본법 제116조에도 규정되어 있는 바와 같이, 본법의 총칙과 벌칙을 제외한 규정들은 적용되지 않고 둘째, 국가공무원 중 주로 소위 비현업국가공무원에 대해서는 국가공무원법이 적용되고 셋째, 지방공무원의 비현업직원 중 일정범위에 대해서는 근로기준감독기관의 직권이 미치지 않는다.

다. 근로시간·휴일상의 특례

다음 사업과 업무에 대하여는 그 특수성 때문에 이상에서 서술한 근로시간·휴일에 관한 원칙이 적용되지 아니한다(근로기준법 제41조);.

① 농·축산·수산업 종사자(1호)

② 관리감독자, 기밀사무취급자(2호)

③ 감시·단속근로 종사자(3호)

①은 기후 등 자연현상에 좌우되는 사업이기 때문이다.

③ 가운데 단속적 근로는 수위, 소·중학교의 잡급직원(用務員), 중역전용차의 운전수 등 실작업시간이 間次的이어서 대기시간이 긴 근로이다. 숙직, 일직 등도 이에 해당한다. 감시근로도, 단속근로도, 적용제외되기 위해서는 근로기준감독서장의 허가가 필요하다.

②의 관리감독자는 실제상 가장 중요한 적용제외이다. 관리직이 됨과 함께 시간외 수당이 지급되지 아니하는 것의 법적인 근거가 여기에 있다. 그 요건(기준)으로서는 a. 노무관리에 관하여 경영자와 일체적 입장에 있을 것, b. 8출사·퇴사에 관하여 엄격한 규제를 받지 않고 자기의 근무에 대해 재량권을 가질 것, c. 그 지위에 어울리는 특별수당(관리직수당)이 지급될 것이 행정지침에 설정되어 있다.

라인에는 없는 스텝직도 라인관리직과 동격이상으로 위지지워 지고, 경영상 중요사항의 전면·입안을 행하는 자는 '관리·감독직'에 해당하는 것으로 되어 있다(1988. 3. 14. 基發 150호). 실제로 기업에 있어서는 중고령층의 증대 속에서 관리직과 직위상 동격인 자는 모두 관리직 취급을 하고, 그 행정지침의 의의는 대단히 크다. 말하자면 연봉제를 도입하는 경우도 스텝관리직을 포함한 '관리직'에 대하여는 시간외 수당을 고려하지 않고 제도를 설계하는 것이 가능한 것으로 되어 있다.

라. 야간근로에 대한 특례

근로기준법 제 64조의 3에서는 만18세 이상의 여자근로자에 대하여는 오후 10시

부터 오전 5시 까지의 야간근로를 시키지 못하도록 하고 있다. 다만, 다음의 경우는 예외로 한다;

1. 제8조 제6호, 제7호, 제13호 혹은 제14호 또는 전화의 사업에 종사하는 자

2. 여자의 건강 및 복지에 유해하지 않은 업무로 명령으로 정하는 업무에 종사하는 자

3. 전조 제4항에서 규정하는 명령으로 정한 것

4. 품질이 급속히 변하기 쉬운 식료품의 제조 또는 가공의 업무 기타 당해 업무의 성질상 심야업이 필요하다고 되는 것으로서 명령으로 정하여진 업무에 종사하는 자(1일의 근로시간이 상시 통상의 근로자의 근로시간에 비해 상당 정도 짧은 것으로 명령으로 정하는 시간 이내인 것에 한한다)

5. 심야업에 종사하는 것을 사용자에게 신청한 자(명령으로 정하는 사업에 종사하는 자에 한한다)로서 당해 신고에 기한 명령으로 정하는 경우에 의해 사용자가 행정관청의 승인을 받은 경우

② 제61조 제2항(심야업금지시간대의 변경) 및 제3항(교대제의 경우의 심야업금지의 완화)의 규정은 만18세 이상의 여자의 심야업에 대해서 준용한다. 이 경우에 동조 제2항 중 「前項」 및 동조 3항 중 「제1항」은 「제64조의 3 제1항」이라고 대체하는 것으로 한다.

③ 전2항의 규정은 제33조 제1항의 규정에 따라서 근로시간을 연장하거나 휴일에 노동시키는 경우에 대해서는 적용하지 않는다.

4. 소 결

위에서 미국, 독일, 일본의 세 나라를 표본으로하여 살펴본 바와 같이, 개별적 근로관계의 적용범위를 확정하는 문제는 정책적인 속성이 강해 각 나라마다 노사관계의 실태에 따라 그 취급방식이 다를 뿐만 아니라 일반론적인 규준을 설정하기가 매우 어렵다고 할 수 있다.

그러나 몇나라의 사례에서 다음과 같은 잠정적인 추론을 도출해 낼 수 있다.

첫째, 사업 또는 사업장의 규모에 따라 일률적으로 적용상의 예외를 인정하고 있는 예는 매우 드물다는 점이다.

일본과 독일의 예에서 나타나는 바와 같이 영세사업장이 가내공업의 성격을 지닐 때에는 그 성격에 착안하여 적용상의 특례를 인정하지 근로자 수를 직접적 매개변수로 하여 특례를 인정하지는 않는다.

연소근로자와 여성근로자에 대해서는 특별취급하는 경우가 많은데, 이는 어디까지나

일반근로자에 비해 이들을 보다 많이 보호하기 위한 배려에서이고 법적용상의 예외를 인정하고자 하는 취지는 아니다

다만 독일의 경우 5인 이하의 사업장에 해고제한법을 적용하지 않도록 하고 있는데, 이는 경영조직법이 5인 이상의 사업장에 적용되는 것(경영조직법 제 1조 참조)과 균형을 맞춘 것이라 할 수 있다.

둘째, 인적 적용범위를 획정하는데 가장 기초적인 개념이라 할 수 있는 근로자의 개념이 나라마다 상이하다는 점이다

미국은 정책적 견지에서 근로자를 파악하고 있기 때문에 통일적인 개념을 포착하기가 용이하지 않고 그 결과 인적 적용범위를 획정함에 있어 특정법률의 정책목표 또는 입법목적에 따라 매우 탄력적인 태도를 취하고 있으며 업무의 내용이나 성격에 따라 광범한 예외규정을 매우 구체적이고 상세하게 제시하고 있다.

독일에서는 유사근로자 개념을 도입하고 있으며 또한 사무직근로자와 생산직 근로자를 구별하여 취급하고 있다. 이는 향후 우리의 법개정에 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

고용형태가 다양해짐에 따라 전통적 의미의 '인적 종속성'은 인정되지는 않지만 자유계약자나 독립영업자와는 달리 여전히 일정한 사업주에 경제적으로 종속되어 있는 노무제공자가 늘어날 것을 예상해 볼 때, 현재와 같이 근로자성의 인정여부에 따라 범적용 여부를 도식적으로 결정하고자 하는 이분법적 접근방식은 다양한 실태에 즉응한 탄력적인 법운용을 기대하기 힘들다고 할 수 있기 때문이다. 새로운 유형의 유사근로자에 대해서는 근로조건의 성질이나 보호의 필요성의 관점에 입각해 법적용 여부를 개별적·구체적으로 파악하여야 할 것이다.

사무직근로자와 생산직 근로자를 구분하여 이원적으로 접근하는 방식은 독일의 전통을 반영한 것이기도 해서 우리의 법제에 이를 도입하기가 용이하지 않을 것이다. 그러나 근로자가 제공하는 업무의 성질이나 내용에 따라 그 취급을 달리하고자 하는 발상법은 향후 탄력적인 노사관계의 정립에 있어 유익한 시사점을 제공한다고 할 수 있다.

셋째, 업종의 특수성, 근로자가 제공하는 업무의 특수성을 감안하여 적용상의 특례를 두고 있음을 발견할 수 있다.

각 나라의 전통이나 노사관계의 실태가 다르기 때문에 예외를 두는 업종이나 업무의 내용은 각 나라마다 상이하지만 업종과 업무를 매개변수로 한 접근방식은 공통적이라 할 수 있다. 이 경우 근로조건의 성질에 따라 개별적으로 예외를 설정하고 있는 사실도 주목할 만하다.

공공기관에 종사하는 자에 대해 법적용상의 예외를 인정하는가의 문제는 나라마다 상이하기 때문에 이를 일률적으로 논할 수 없다.

네째, 근로시간과 관련한 규정에서 적용상의 특례가 자주 발견된다는 점이다.

근로시간은 근로조건 중 법규제의 정도가 가장 강할 뿐만 아니라 법에서 정한 기준

이 최저기준으로서 보다는 표준기준으로 작용하기 때문에 각 나라의 실태를 가장 정확히 반영한다.

최근 일본에서 법정근로시간의 단축을 입법적으로 추진함에 있어 사업의 규모나 업종의 성질에 착안하여 단계적으로 실시하는 방식도 매우 시사적이다.

다섯째, 기업의 법준수능력 또는 근로자의 경제적 능력을 감안하여 적용상의 예외를 인정한 경우도 발견된다.

연간 거래총액이 50만 달러 이상인 사업에 대해서만 FLSA가 적용되도록 한 미국의 예는 법의 실효성과 관련해 기업의 법준수능력을 감안한 것으로 풀이할 수 있다.

또한 관리직 근로자에 대해서도 각 나라마다 특칙을 두고 있는 바, 이는 근로자의 경제적 능력을 감안한 것으로 볼 수 있다.

V. 종합적 검토

1. 적용제외의 합헌성 여부

종업원 수에 따른 적용배제가 (i) 평등원칙의 위반 여부 (ii) 입법정책의 재량범위의 문제로 논의된 바 있음. 헌법재판소는 그 합헌성을 인정한 바 있다..

*** 헌법재판소 1999.9.16. 98헌마310 결정 근로기준법제10조제1항 위헌확인**

아파트 경비원으로 3년 근무하고 퇴직하는 근로자가 1월분의 평균임금만을 퇴직금을 받게 되자 법정퇴직금지급의무에 관한 규정을 4인 이하 사업장에 적용되는 규정에서 제외시키고 있는 근거규정인 근기법 제10조의 위헌성이 다투어진 사안이다.

헌법재판소는 다음과 같은 이유로 평등원칙 위반이 아니라고 판시하였다.

'상시 사용 근로자수 5인'이라는 기준을 분수령으로 하여 근로기준법의 전면적용 여부를 달리한 것은, 근로기준법의 확대적용을 위한 지속적인 노력을 기울이는 과정에서, 한편으로 영세사업장의 열악한 현실을 고려하고, 다른 한편으로 국가의 근로감독능력의 한계를 아울러 고려하면서 근로기준법의 법규범성을 실질적으로 관철하기 위한 입법정책적 결정으로서 거기에는 나름대로의 합리적 이유가 있다고 할 것이므로 평등원칙에 위배된다고 할 수 없다.

이러한 헌재결정의 기본적인 입장은 그 후에도 비슷한 사안에서 반복적으로 인용되고 있다.

예컨대 건설공사의 규모에 따라 산재법의 적용 여부를 달리하고 있는 산재법 규정에 대해서도(헌법재판소 2003.7.24. 2002헌바51 결정), 평균임금이 높은 경우 최고보상액을 제한한 산재법 규정에 대해서도(헌법재판소 2004.11.25. 2002헌바52 결정) 모두 평등원칙 위반이 아니라고 판시하였다..

참고로 독일의 경우에도 5인 이하 영세사업장(Kleinebetriebe)에 대해서는 해고보호법이 적용되지 않는다고 규정하고 있는 해고보호법 제23조 1항 2문은 헌법과 합치된다고 결정한 바 있다(BVerfG, 1BvL 15/87 vom 27.1.1998)

*** 독일 헌법재판소 주요 결정내용**

㉮ 해고보호법 제23조 1항 2문은 헌법 제12조 1항("모든 독일국민은 직업, 일자리, 직업교육자리(Ausbildungsstaette)를 자유롭게 선택할 권리를 가진다. 직업활동은 법률에 의해서 혹은 법률을 토대로 하여 규율될 수 있다")과 합치됨.

- 헌법 제12조1항에 의해 보호되는 일자리 유지라는 근로자의 이익이 존재하는 반면 자신의

기업에서 자신의 생각에 따라 근로자를 고용하고 자신이 정한 기준에 따라 그 수를 제한할 수 있는 사용자의 이익이 존재한다. 이러한 이익들을 공정하게 조정하게 되는 입법자에게는 광범위한 형성의 자유(Gestaltungsfreiraum)가 인정된다. 갈등상황에 대한 중요한 경제적, 사회적 기본조건의 평가는 입법자의 정치적 책임, 즉 그 규정의 장래의 전개 및 영향에 대한 예측 하에 놓이게 된다. 이는 이해관계 상황에 대한 가치 평가, 즉, 상호간의 대립되는 이익들 중 중요도의 결정과 보호필요성의 결정에 관하여 적용된다. 따라서 헌법적 보호의무에 대한 침해는 하나의 기본권의 지위가 다른 계약당사자의 이익보다 하위에 놓이게 되는 경우에 기본권의 의미와 범위를 고려하여 적절한 조정이 더 이상 논의될 수 없는 상황에서 확인될 수 있다. 이에 따라 평가하면 영세사업장 적용제외 규정은 헌법 12조 1항에 위배되지 않는다. 입법자는 근로계약 당사자들간의 이해관계를 조정하였고 이는 기본권규범으로부터 도출되는 보호의무를 충족시킨다. 서로 상반되는 이익들이 적절하게 고려되어진 것이다.

- 일반적으로 영세사업장에서는 경영자 자신도 현장에서 함께 일하게 되고 그에 따라 각 근로자들과의 신뢰관계는 특별한 의미를 갖게 된다. 또한 미약한 자금이 중요한 의미를 가지기도 한다. 영세사업장은 근로관계 해지시 보상금을 지불할 능력이 없는 경우 혹은 보다 소수의 능력있거나 필요하거나 마음에 드는 직원과 함께 업무를 부담할 능력이 되지 않는 경우가 빈번하다. 따라서 대기업에 비해 영세사업장에게는 해고보호절차를 위한 비용이 심각한 부담이 된다.
- 해고보호법 규정이 개입하지 않게 되는 경우 근로자는 민법상 일반조항에 의해 관습이나 신의에 위반되는 사용자의 해고권 행사로부터 보호된다. 이러한 일반조항의 범주 내에서도 기본권의 객관적 내용이 주시되어야 한다. 무엇보다도 헌법 제12조 1항으로부터 중요한 원칙들이 도출된다. 헌법상 부여되는 사적 재량에 의한 일자리 상실로부터의 최소한의 보호는 어떤 경우에도 보호된다. 개별적인 경우에 이러한 보호가 어느 범위까지 미치는가는 노동법원(Arbeitsgericht)에 의해 결정될 수 있다. 그러한 가치평가의 출발점은 해고보호법 제23조 1항을 통한 법률상 해고보호에 대한 입법자의 한계설정에 대한 존중이다.

㉯ 해고보호법 제23조 1항 2문은 헌법 제3조 1항(모든 인간은 법률앞에서 평등하다)에 합치됨: 대기업 근로자들에 비해 영세기업근로자들을 불이익 처우 하는 것이 헌법에 위배되는지 여부가 문제되었음.

- 입법자는 풀타임으로 고용된 근로자 수(주간 10시간 미만, 월간 45시간 미만 근무하는 파트타임 근로자수는 고려하지 아니함)에 의해 사업장 규모를 정하고 있다. 모든 법률상의 규정은 일반적이어야 한다. 따라서 입법자는 대량적인 현상(Massenerscheinung)에 있어서 강제되고 또한 기존의 경험으로부터 나오는 전체적인 관념(Gesamtbild)에 근거하는 입법자의 결정도 정당화될 수 있다. 사용자측에서의 해고는 전형적인 대량적 현상이다. 노동분업적 경제와 복잡한 공적 행정이 기능하기 위해서는 명확한 규율들이 필수적이다. 이러한 규율들은 근로계약의 양 당사자의 이익을 다룬다. 이는 단순하고 쉽게 확인할 수 있는 사실에 근거하여 해고보호법의 사업장 적용범위를 결정하는 것을 정당화 한다.
- 밀접하고 개인적인 공동작업, 특히 사업장 내에서의 사용자의 근로자와의 공동작업, 미약한

재정 및 관리능력 등은 사용자에게 해고보호법의 규정들을 강제하는 것보다는 해고권의 자유로운 행사를 인정하기 위한 좋은 이유들이다.

- "사업(Betrieb)"은 일반적으로 사용자가 특정한 노동기술적 목적을 추구하는 조직화된 통일체로서 이해된다. 경우에 따라서는 대규모 기업들의 일부분들도 이러한 사업장 개념에 포함될 수 있는데 이 경우에는 영세사업장 근로자에 대한 차별대우를 정당화하는 관점에 부합되지 않게 되고 이는 사실상 헌법 제3조 1항에 합치 되지 않는다.
- 해고보호법 제23조 1항 2문의 역사적 배경: 본래 경영조직법상 해고보호가 성문화되었고 이는 대표기관(Vertretung)이 존재하는 사업장에 제한되었었다.

현재의 상황에서 시장에 미치는 파급효과를 감안하여 단계별, 특성별 예외 적용은 어느 정도 불가피한 측면도 있다 할 것이다. 그러나 원론적 입장에서 보면 국제규범이나 헌법의 평등권 조항에 비추어 규모별 차별 적용은 바람직하다고 보기는 어렵다[45]. 따라서 향후 법개정이나 제도정비의 기본방향은 가급적 규모별 적용 예외를 축소하는 쪽으로 가닥이 잡혀야 할 것으로 보인다.

2. 확대 적용시에 고려되어야 할 사항에 대한 검토

제II장에서 살펴본 바와 같이 우리나라에서 그간 영세사업장에 근로기준법의 적용을 유보해 왔던 사유를 보면, 행정감독상의 어려움이나 사용자의 법준수능력의 미비와 같은 현실적인 사정을 감안한 것도 있고 현실과의 괴리가 심해 실효성이 의심스러운 규정 또는 제도적 타당성이 논란될 소지가 있는 규정과 같이 조항 자체의 성격에 착안한 것도 있다.

외국에서 법적용상의 특례를 인정하는 사유를 보면 업종의 특수성과 업무의 내용에 즉응하여 탄력적으로 법을 법운용하기 위한 경우, 근로자 개념의 재정립과 관련하여 구체적 타당성을 도모하고자 하는 경우를 들 수 있다. 적용상의 특례를 인정하는데 있어서도 규정 자체의 성격과 그 나라의 노사관계의 실태를 감안하여 개별적· 구체적으로 접근하고 있으며 그 결과 매우 상세한 규정을 마련하고 있다는 점이 눈에 띈다. 특히 노동의 유연성 제고와 관련하여 근로시간에 관해서는 모든 나라가 특별취급하고 있다는 점도 눈여겨 볼 만하다.

---

45) 이와 관련 정인섭 교수의 직설적 비판을 경청해 봄직하다 "적어도 4인 이하 사업장에 대해서 근기법의 적용을 확대할 경우에 증가하게 되는 근로감독행정의 부담이 도대체 무엇을 말하는지도 가늠해 보아야 할 것이다. 비유가 적절한 것인지는 모르겠으나 수사기관의 업무가 과중하다고 해서 어떤 행위를 범죄가 아닌 것으로 —예를 들면 4인 이하 사업장에서 발생하는 업무상횡령은 업무상횡령이 아니라는 식으로— 분류해서 업무상횡령죄 규정의 적용을 배제하는 수도 있는가?" 정인섭, 근기법 개정방안 검토의견, 근로기준법 개정을 위한 공청회(비정규·소외 노동자보호/근로기준의 실효성 확보), 단병호의원/노동인권 실현을 위한 노무사 모임, 2005.8

이하에서는, 향후 우리나라에서 4인 이하의 영세사업장에 근로기준법의 확대적용을 재정비함에 있어 어떠한 입법정책적 관점이 필요한가라는 문제의식을 가지고, 위의 제요인들을 검토해보고자 한다.

1) 행정감독능력

근로기준법이 보호법으로서의 실효성을 가지기 위해서 현행법상으로 세가지 방법을 사용하고 있다고 할 수 있다. 즉 법상의 최저기준에 미달하는 근로조건을 근로계약의 내용으로 하였을 경우 그 계약 자체를 강해법규 위반으로 무효화하는 방법과 근로기준법을 준수하지 않았을 경우에 벌칙의 제재를 가하는 방법, 근로기준법 위반시 행정구제제도를 두는 방법이 바로 그것이다.

후자의 벌칙을 가하기 위해서는 위법사항을 적발하는 등의 행정적·사법적 조치가 뒤따라야 함은 물론이다. 이러한 점에서 행정감독능력은 법적용확대시에 고려되어야 하는 중요 변수라고 할 수 있다.

1998년 시행령 개정 이전의 구 근로기준법시행령에서는 중간착취의 배제(제8조), 최저연령(제62조) 및 연소자증명서 비치의무(제64조), 근로감독관의 비밀준수의무(제106조) 및 사실묵과에 관한 조항(제111조)을 영세사업장에 대해 적용제외하고 있었는데, 이는 행정감독능력을 고려한 것이라 할 수 있다. 그러나 1998년 시행령 개정시에는 이러한 내용은 모두 4인 이하의 영세사업장에 대해서도 적용되도록 하였다.

그러나 여전히 근로기준법상의 부당해고에 따른 노동위원회에의 구제신청제도(제33조)[46] 및 근로조건 위반시 노동위원회에의 손해배상청구(제26조 제2항)에 대해서는 4인 이하 사업장의 경우에 적용제외하도록 하고 있다.

외국의 예에서 이러한 요인이 입법정책적으로 어느 정도 반영되는지에 대해서 이를 일률적으로 평가할 수는 없지만, 본고에서 살펴본 바에 의하면 별로 중요한 변수로 취급되는 것같지는 않다.

우리의 근로기준법이 도입시부터 외국법을 계수한 관계로 실제와의 괴리가 있었고 이를 행정적으로 온전히 뒷받침하기가 불가능하였다는 점을 감안하면, 앞으로도 당분간은 행정감독능력이라는 요인을 무시할 할 수는 없을 것이다. 그러나 근로기준법이 입법취지에 충실하게 운용되기 위해서는 그에 필요한 만큼 행정적 지원이 따라야 하지, 행정부의 사정을 이유로 최저한도의 기준이 준수되지 않아도 된다는 것은 정당화되기 힘들 것이다.

이러한 점에서 헌법상의 근로권 보장취지를 살리고 근로자의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 국가정책적 차원에서 행정감독능력을 제고시키는데 적극적인 노력을 경주하

46) 물론 부당해고에 따른 노동위원회구제제도를 적용제외한 것은 근로기준법 제30조 제1항 및 제31조의 해고제한규정이 적용제외되는 것과 관련이 있다.

여야 할 것이다.

2) 사용자의 법준수능력

사용자의 법준수능력을 적용제외사유로 인정하고 있는 예는 외국의 경우는 매우 드물다. 다만 미국에서 연간 매출액 50만 달러 이상인 기업에 대해서만 연방공정근로기준법(FLSA)이 적용되도록 한 예를 발견할 수 있다.

우리나라의 경우, 제30조 및 제31조 등의 해고제한 규정, 제34조의 퇴직급여제도, 제45조의 휴업수당, 제73조 육아시간, 제7장의 기능습득, 제10장 기숙사에 관한 규정, 10인 이상의 사업주에게 작성의무가 있는 제9장 취업규칙에 관한 장 등은, 사용자의 경제적 능력 등을 감안하여 영세사업장에 적용되지 않도록 한 것이라고 할 수 있다.

우리나라의 근로기준법에서는 ILO 기준을 상회하는 내용을 규정하기도 하고 그로 인한 경제적 비용은 주로 사용자로 하여금 부담하게 하고 있기 때문에, 이 점 또한 전혀 무시할 수는 없다.

3) 업무의 특수성에 따른 개별적 접근

제 3장에서 살펴본 바와 같이 미국, 독일, 일본에서는 공히 업종의 특수성을 감안하여 법적용상의 특례를 광범하게 인정하고 있다. 이 경우 근로조건의 성질에 따라 개별적으로 예외를 설정하는 방식을 취하는 것이 일반적이다. 우리와 같이 전부 아니면 전무의 이분법은 이들에게 친하지 않다.

노동의 유연성과 탄력성을 제고하기 위해서는 이러한 개별적·구체적 접근방식이 보다 효과적일 것이다. 향후 근로시간제를 재정비함에 있어 특히 유용하다 할 것이다.

4) 규정의 성격 (실효성, 타당성, 유연성의 문제)

규정의 성격에 착안하여 개별적으로 법적용상의 특례를 인정하는 방식도 외국에서는 일반적이다. 앞에서 살펴본 바와 같이 미국의 공정근로기준법에서는 최저임금, 근로시간, 연소자근로의 각각의 내용에 따라 적용 범위를 달리 설정하고 있다. 또한 근로시간에 관해서는 다른 근로조건과 달리 특별취급하고 있는 점도 일반적인 현상이다.

위의 예는 규정에 내재하는 성격과 관련된 것이라고 한다면, 우리나라의 경우에는 연혁적, 입법정책적 견지에서 규정의 실효성 또는 타당성이 미흡한 규정을 들 수 있다. 즉 근로시간제와 같이 법과 현실과의 괴리가 있어 실효성이 떨어졌던 규정, 생리휴가 등과 같이 그 제도적 타당성에 관하여 논란의 여지가 있는 규정이 그것이다.

우선 근로시간제와 휴식 및 휴가에 관한 규정은 근로기준법 제정당시부터 일반사업

장에서도 제대로 지켜지지 않고 장식물화된 경우가 많았던 조항이라 할 수 있다. 그러나 최근에 들어와 우리의 실근로시간도 단축되어 법정근로시간에 근접해 가고 있고 근로시간은 가장 기본적인 근로조건이라는 점을 감안한다면 영세사업장에도 법적용을 배제하는 것을 원칙으로 하는 것은 바람직하지 않다 할 것이다. 다만, 근로기준법에는 노동시장의 규제완화 또는 유연성 제고의 측면에서 탄력적 근로시간제, 선택적 근로시간제, 근로시간 계산의 특례 등이 도입되어 있는데, 이는 곧바로 영세사업장에 적용하기는 힘들 것이다. 즉, 영세사업장의 근로자는 대등한 계약당사자로서의 입지가 취약하기 때문에 일반사업장과 동일하게 취급해서는 안될 것이다.

부당해고 등을 이유로 하는 노동위원회에의 구제신청제도는 1989년도 도입된 이래 구제명령의 법적 성격, 그 실효성을 둘러싸고 다툼이 있기 때문에 노동위원회의 기능강화 방안과 함께 재검토되어야 할 것으로 보이고 인다.

5) 근로시간에 대한 특별취급

각국의 예에 비추어 보면 근로시간에 대해서는 여타의 근로조건과 달리 그 나라의 노사관계의 실태를 반영하여 매우 구체적이고 상세한 규정을 마련하고 있다.

대체로 업종의 특수성, 업무의 성격이 반영되고 일본의 경우에는 사업장 규모도 반영되기도 한다. 이에 비해 우리의 근로기준법은 매우 포괄적으로 적용되고 있음을 알 수 있다.

그러나 근로시간이 가장 기본적인 근로조건임을 감안한다면 현재와 같이 영세사업장에 휴일, 휴게만을 적용시키고, 그 외에는 모두 적용을 배제하는 입법태도는 바람직하지 않다. 영세사업장의 사정에 맞는 휴가제도 등이 보장되는 선에서 우리 상황에 적합한 방향으로 개별적인 검토가 행해져야 할 것이다.

6) 사업장 규모

외국의 예에 비추어 보면 사업장의 규모가 영세하다고 해서 일률적으로 적용상의 예외를 인정하는 경우는 매우 드물다는 점은 앞서 언급한 바대로이다.

이는 현재 우리나라와 같이 영세사업장의 성격을 고려하지 않고 무차별적으로 근로기준법을 부분 적용하는 방식이 합리적이지 않다는 점을 반증한다. 또한 영세사업장에도 근로기준법을 적용하는 것이 원칙이라는 점을 방증해 주기도 한다.

일본이나 독일이 가내공업이라는 매개변수를 사용하여 영세사업장에 대한 특례를 설정하듯이, 우리의 영세사업장의 특질을 다각적으로 분석하여 보다 세분화된 법정비가 필요하다 할 것이다.

7) 근로자 개념의 재정립

우리나라에서도 산업구조조정기에 접어들면서 고용형태가 다양화되고 그에 따라 경영자의 노무관리 기법도 다양해짐에 따라, 제조업에서의 근로제공방식과는 매우 생소한 노무제공이 증가하고 있다.

따라서 '인적종속성'이라는 전통적인 개념적 표지(Merkmal)만으로서는 포섭할 수 없는 노무제공자群이 증대하고 있기 때문에 이와 관련한 근로자 개념을 새로이 정립해야 할 필요가 있다. 또한 근로자인가 아닌가에 따라 법적용여부가 일률적· 도식적으로 결정되는 방식도 바람직하지 않을 것이다. 판례나 행정해석에 따르면 위탁수금원이나 보험모집인과 같이 도급제적 성격을 지니는 노무제공자의 근로자성을 부정하고 있는데, 그 타당성은 별론으로 하더라도, 이들보다 자유로운 노무제공자가 증대하고 있는 현실에서 법운용상의 예측가능성을 기대하기가 매우 힘들다. 이 점은 향후 근로기준법의 패러다임 변화를 모색함에 있어 종합적, 유기적으로 검토되어야 할 것이다. 그러나 본고에서 목적하는 바의 영세사업장에의 법적용확대를 논의함에 있어 직접적으로 이를 원용하기는 힘든 측면이 있다.

3. 확대적용의 구체적 범위

앞에서 살펴본 바와 같이, 1998년 시행령 개정 이전부터 한국노총에서는 영세사업장에도 근로기준법이 전면 적용될 것을 주장하였고, 민주노총에서는 부분적용을 원칙으로 하되 그 적용대상을 대폭적으로 확대해줄 것을 요구하였다.

현재로서는 행정감독능력, 사용자의 법준수능력 등의 요인으로 말미암아 4인 이하의 영세사업장에 대하여 근로기준법을 전면적용하는 것은 다소 무리이기 때문에, 1998년에 시행령을 개정하면서 4인 이하 영세사업장에 적용되는 법규정의 범위를 구체적으로 정하였다. 그러나 최근 영세사업장의 다양한 특성과 영세사업장 근로자들의 근로조건 악화, 다양한 고용형태의 출현, 근로기준법의 수차례에 걸친 개정 등으로 인해 현행 영세사업장에 대한 근로기준법의 적용배제대상이 타당한지, 그리고 그 적용배제대상을 어느 선으로 재조정하느냐가 또하나의 중요한 문제가 되고 있다.

영세사업장에의 적용확대는 기본적으로 입법정책적 선택을 내려야 하는 문제이기 때문에, 원리적 입장에 따를 수 만은 없고 법의 취지나 현실적 여건 등을 종합적으로 고려하여 합목적적인 판단을 하여야 할 것이다.

본고에서 검토한 내용을 토대로 필자 나름대로 제시하는 대안은 다음과 같다[47].

47) 연구회의 내부토론을 거쳐 의견을 조율한 후 최종보고서에 반영할 예정임. 토론을 위한 편의적인 것임.

1) 영세사업장에도 적용되어야 할 조항

가. 근로기준법 제30조 제1항 및 제31조의 해고제한제도

나. 법 제33조의 노동위원회에의 부당해고구제신청

다. 제26조 제2항 노동위원회에의 손해배상청구 등

라. 제4장 근로시간과 휴식 중 휴가,조항
- 연차휴가 및 연차휴가사용촉진제도, 보상휴가제 등

2) 불포함

가. 제23조 계약기간

나. 제45조 휴업수당

다. 제63조 제2항 및 제68조 18세 이상 여성근로자에 대한 보호조항

라. 제71조 생리휴가

마. 제73조 육아시간

바. 제7장(기능습득), 제9장(취업규칙), 제10장(기숙사)

3) 검토사항

*. 2001년 시행령 별표 1의 개정 이후 신설된 조항들
- 미지급 임금에 대한 지연이자(제36조의2), 유·사산 보호휴가(제72조 제2항)